

วารสารกฎหมาย สุโขทัยธรรมาราช

SUKHOTHAI THAMMATHIRAT LAW JOURNAL



ISSN 0857-9776

ปีที่ 23 ฉบับที่ 1

มิถุนายน 2554

❖ บทความทั่วไป

- วิธีการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพ : ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
- THAI TRADITIONAL MEDICINE PROTECTION (Part II)
- มาตรการปรับค่าคาร์บอนก่อนเข้าพรมเขตและตลาดคาร์บอน : กลไกในการลดภาวะโลกร้อนกับการเตรียมพร้อมของประเทศไทย
- วิวาทย้อนคอก
- พยานวัตถุที่ขุดได้
- ปัญหาทางกฎหมายของกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
- ความรับผิดชอบทางอาญาของการลักลอบรูปทรงที่ผิดที่

❖ แนะนำกฎหมายใหม่

❖ วิทยาค้นหนังสือ

❖ คำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ ประกอบชุดวิชา

❖ วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา



บทกวี ประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วิเคราะห์ข้อสอบ ชุดวิชา



กฎหมายแพ่ง 1 : บุคคล นิติกรรม สัญญา

อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์

คำถาม

นายสุกร์ทำสัญญาซื้อโคนมจากฟาร์มของนายเสาร์จำนวน 100 ตัว ราคา 5,000,000 บาท โดยตกลงให้นายสุกร์เป็นผู้คัดเลือก โดยนัดให้มาคัดเลือกโคนมและรับกลับไปในอีก 3 วันข้างหน้า คืนก่อนถึงวันนัดหมายได้เกิดพายุใหญ่พัดเข้าที่ฟาร์มของนายเสาร์ ทำให้โคนมตายไปทั้งหมด นายเสาร์จึงไม่สามารถส่งมอบโคนมให้นายสุกร์ได้ ดังนี้ นายเสาร์มีสิทธิเรียกให้นายสุกร์ชำระราคาโคนมทั้งหมดได้หรือไม่ เพราะเหตุใด อธิบาย

แนวตอบ

มาตรา 370 ถ้าสัญญาต่างตอบแทนมีวัตถุประสงค์เป็นการก่อให้เกิดหรือโอนทรัพย์สินในทรัพย์สินเฉพาะสิ่งและทรัพย์สินนั้นสูญหรือเสียหายไปด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษลูกหนี้ไม่ได้ใช้ ท่านว่าการสูญหรือเสียหายนั้นตกเป็นพับแก่เจ้าหนี้

ถ้าไม่ใช่ทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง ท่านให้ใช้บทบัญญัติที่กล่าวมาในวรรคก่อนนี้บังคับแต่เวลาที่ทรัพย์สินนั้นกลายเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งตามบทบัญญัติแห่งมาตรา 195 วรรคสองนั้นไป

มาตรา 372 นอกจากกรณีที่กล่าวไว้ในสองมาตราก่อน ถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพับวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ไม่ได้ใช้ ท่านว่าลูกหนี้หาสิทธิจะรับชำระหนี้ตอบแทนไม่

ถ้าการชำระหนี้ตกเป็นพับวิสัยเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งอันจะโทษเจ้าหนี้ได้ ลูกหนี้ก็หาเสียสิทธิที่จะรับชำระหนี้ตอบแทนตอบแทนไม่...

วินิจฉัย

สัญญาซื้อโคนมจำนวน 100 ตัว เป็นสัญญาต่างตอบแทน ที่มีวัตถุประสงค์เป็นการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน แต่การที่นายสุกร์ตกลงว่าจะคัดเลือกโคนมในอีก 3 วันข้างหน้า กรณีจึงถือไม่ได้ว่าโคนม 100 ตัวเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง เพราะนายสุกร์ยังมิได้คัดเลือกว่าจะให้ส่งมอบโคนมตัวไหน สัญญาซื้อขายโคนมระหว่างนายสุกร์กับนายเสาร์จึงไม่ตกอยู่ในบังคับของมาตรา 370

เมื่อเกิดพายุใหญ่พัดเข้าที่ฟาร์มของนายเสาร์ทำให้โคนมตายไปทั้งหมด เป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้การชำระหนี้กลายเป็นพับวิสัย จึงต้องนำมาตรา 372 มาบังคับใช้แทน ซึ่งการที่โคนมตายไปทั้งหมดก็มิได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนั้น นายเสาร์จึงหาสิทธิเรียกให้นายสุกร์ชำระราคาโคนมแก่ตนไม่ได้

วิเคราะห์

จากโจทย์นักศึกษาส่วนใหญ่วินิจฉัยว่าเป็นเรื่องของสัญญาต่างตอบแทน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นการโอนทรัพย์สินเฉพาะสิ่ง และสัญญาซื้อขายโคนมระหว่างนายสุรกรและนายเสาร์เกิดขึ้นแล้ว โคนมจึงเป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งตามมาตรา 370 และมีนักศึกษาบางส่วนวินิจฉัยว่า สัญญาซื้อขายโคนมเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่มีเงื่อนไขบังคับก่อนตามมาตรา 371 เนื่องจากมีการตกลงกันให้คัดเลือกโคนมและรับกลับไปในอีก 3 วันข้างหน้า แต่การนี้เห็นว่าสัญญาซื้อขายโคนมเป็นสัญญาต่างตอบแทนก็ตาม การที่นายสุกรยังมีได้คัดเลือกโคนมเพื่อส่งมอบ จึงทำให้โคนมยังมีได้เป็นทรัพย์สินเฉพาะสิ่งตามมาตรา 370 อีกทั้งสัญญาซื้อขายโคนมก็มีใช้สัญญาต่างตอบแทนที่มีเงื่อนไขบังคับก่อน ดังนั้นจึงต้องนำหลักกฎหมายมาตรา 372 มาปรับใช้แทน การที่โคนมตายไปเพราะเกิดพายุใหญ่ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งเป็นเรื่องของการชำระหนี้ตกเป็นพันวิสัยอันจะโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ ดังนั้น นายเสาร์จึงไม่มีสิทธิที่เรียกให้นายสุกรชำระราคาโคนมให้แก่ตนได้ตามมาตรา 372



กฎหมายแพ่ง 2 : หนี้ ละเมิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรรัตน์ ประจวบจักษ์

คำถาม

ก ขับรถยนต์ด้วยความเร่งรีบไปต่างจังหวัดเพราะกลัวไม่ทันงานบวชเพื่อน ข นั่งมากับ ก ปรากฏว่า ก ขับรถยนต์หลบหลุมไม่ทัน รถยนต์ตกหลุมเป็นเหตุให้ ข ซึ่งนั่งหลังได้รับบาดเจ็บ ข จึงเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก ก ก ไม่ยอมชดใช้อ้างว่า ข เป็นผู้ชอนนั่งมาด้วยเอง ก จึงไม่ต้องรับผิดชอบ อีกทั้ง ข บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ท่านเห็นด้วยกับข้ออ้างของ ก หรือไม่เพราะเหตุใด

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

มาตรา 420 บัญญัติว่า “ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น”

มาตรา 437 วรรคแรก บัญญัติว่า “บุคคลใดครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอย่างใด ๆ อันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล บุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบเพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้นเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการเสียหายนั้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ต้องเสียหายนั่นเอง”

การที่ ก ขับรถยนต์ด้วยความเร่งรีบไปต่างจังหวัดเพราะกลัวไม่ทันงานบวชเพื่อนนั้น เป็นกรณีที่ ก ขับรถโดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้หลบหลุมไม่ทัน ทำให้ ข ซึ่งนั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนั้น และการบาดเจ็บนั้น เป็นกรณีที่ ก ทำละเมิด โดยเป็นความรับผิดชอบในการกระทำโดยประมาทเลินเล่อของตนเองตามมาตรา 420

เมื่อ ก รับผิดชอบโดยละเมิดตามมาตรา 420 แล้ว ก็ไม่เป็นความรับผิดชอบตามมาตรา 437 อีก และการบาดเจ็บนั้นอีก เพราะความรับผิดชอบของบุคคลผู้ครอบครองหรือควบคุมดูแลยานพาหนะอันเดินด้วยเครื่องจักรกลจะนำมาใช้ต่อเมื่อเป็นความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นโดยไม่จงใจไม่ประมาทเลินเล่อ

การที่ ข ยินยอมนั่งรถมากับ ก ด้วย ไม่เป็นเหตุให้ ก ปฏิเสธความรับผิดชอบได้เพราะความเสียหายที่ได้รับแม้จะเล็กน้อยก็ตาม ก็เป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของ ก ดังนั้น ข สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตามมาตรา 420

สรุป ไม่เห็นด้วยกับข้ออ้างของ ก เพราะ ก ทำละเมิดต่อ ข

วิเคราะห์

ความรับผิดตามมาตรา 437 นี้ เป็นกรณีความรับผิดโดยเด็ดขาด ผู้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ต้องรับผิดแม้ไม่มีเจตนาหรือประมาทเลินเล่อ เป็นกรณีที่ต้องรับผิดเพราะกฎหมายบัญญัติเมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน จากโจทย์จะเห็นว่า ก. มีการกระทำและประมาทเลินเล่อ เนื่องจากขับรถด้วยความเร็วรีบทำให้หลบหลุมไม่ทันเป็นเหตุให้ ข. ได้รับความเจ็บในกรณีนี้ ก. จึงทำละเมิดตามมาตรา 420 และทั้งความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำของ ก. เมื่อรับผิดชอบตามมาตรา 420 แล้ว จึงไม่ต้องพิจารณา มาตรา 437 อีก ความรับผิดฐานละเมิดตามมาตรา 420 นั้นไม่มีข้อยกเว้นความรับผิด ดังนั้น เมื่อ ก. กระทำโดยประมาทเลินเล่อทำให้ ข. บาดเจ็บแม้จะเล็กน้อยก็ตาม ก. ก็ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ข.



กฎหมายอาญา 1 : ภาคทบทวนคดีทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ลาวัลย์ หอนพรัตน์

คำถาม

สุนัขบ้าไม่มีเจ้าของวิ่งไล่จะกัดบี้ม บี้มวิ่งหนีสุนัขก็วิ่งไล่ บี้มเห็นบ้านของบอยประตูเปิดอยู่ จึงวิ่งเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในบ้านบอย เช่นนี้บี้มต้องรับผิดชอบบุกรุกหรือไม่

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 67 บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำความผิดด้วยความจำเป็น

(1) เพราะอยู่ในที่บังคับ หรือภายใต้อำนาจซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ หรือ

(2) เพราะเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายที่ใกล้จะถึงและไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นโดยวิธีอื่นใดได้ เมื่ออันตรายนั้นตนมิได้ก่อให้เกิดขึ้นเพราะความผิดของตน

ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นการเกินสมควรแก่เหตุแล้ว ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ"

จากการมีปัญหา การที่สุนัขบ้าไล่จะกัดนั้นเป็นอันตรายที่เกิดขึ้นและใกล้จะถึงแล้ว คือถ้าบี้มไม่วิ่งหนีหรือวิ่งหนีไม่ทันก็จะถูกกัดแน่นอน และข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าอันตรายนั้นบี้มเป็นผู้ก่อ กล่าวคือไปยั่วยุ ไปแหย่สุนัขหรือไปทำให้สุนัขมีอาการบ้าเกิดขึ้นแต่อย่างไร ส่วนการที่วิ่งหลบเข้าไปในบ้านบอยก็เพื่อให้ตนเองพ้นจากการถูกสุนัขกัด ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับกรณีการถูกสุนัขกัดซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกายและชีวิตได้แล้ว ก็ถือว่าพอสมควรแก่เหตุ ดังนั้น การเข้าไปในบ้านผู้อื่นเป็นความผิดฐานบุกรุก แต่กฎหมายยกเว้นโทษให้

วินิจฉัย

บี้มผิดฐานบุกรุกแต่กฎหมายยกเว้นโทษให้ เข้าหลักเกณฑ์การกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา 67 (2)

วิเคราะห์ข้อสอบ

ข้อสอบข้อนี้ผู้ออกเจตนาให้นักศึกษาแยกให้ออกระหว่างอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์เรื่องการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 67 กับอันตรายในเรื่องการกระทำความผิดด้วยความจำเป็นตามมาตรา 68 (2)

โดยเฉพาะภยันตรายที่เกิดจากการกระทำของสัตว์ นักศึกษาต้องแยกให้ออกว่าการกระทำของสัตว์กรณีใดเป็นประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย และกรณีใดเป็นภยันตรายทั่วไป ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าถ้าภยันตรายเกิดจากสัตว์ ถ้าเป็นสัตว์ไม่มีเจ้าของก็จะเป็นภยันตรายตามมาตรา 68 (2) แต่ถ้าเป็นภยันตรายที่เกิดจากสัตว์ที่มีเจ้าของก็จะถือว่าเป็นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมาย เพราะถือว่าผู้กระทำละเมิดต่อกฎหมายคือเจ้าของสัตว์นั่นเอง



กฎหมายอาญา 2 : ภาคความผิด

รองศาสตราจารย์ สุจินตนา ชุมวิสูตร

คำถาม

นายสังข์ลักนาฬิกาของนายแดง แต่นายแดงเจ้าของจับได้ นายสังข์รับสารภาพผิด และยอมคืนนาฬิกาให้นายแดงไป โดยนายสังข์บอกนายแดงว่า ตนได้บอกกับนายหมึกไว้ว่าจะนำนาฬิกาที่ลักได้ไปขายให้นายหมึกในราคาถูก เพราะเห็นว่านายหมึกไม่เคยมีนาฬิกาใช้เลยในชีวิต นายแดงไม่เอาโทษนายสังข์และมอบนาฬิกาเรือนนั้นให้นายสังข์ไปขายให้นายหมึก นายหมึกรู้เรื่องการที่นายสังข์ไปลักนาฬิกาของนายแดง แต่ด้วยความอยากได้จึงรับซื้อไว้ในราคาถูก ดังนี้ นายสังข์และนายหมึกต้องรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญารึนใดหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 334) บัญญัติว่า “ผู้ใดเอาทรัพย์สินของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา นายสังข์ได้ลักนาฬิกาของนายแดงไป แต่นายแดงเจ้าของจับได้ นายสังข์รับสารภาพผิดและยอมคืนนาฬิกาให้นายแดงไป กรณีดังกล่าวจะเห็นว่าการกระทำของนายสังข์ที่ลักนาฬิกาของนายแดงเป็นการกระทำความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จแล้ว แม้ต่อมาเมื่อนายแดงจับได้ นายสังข์ได้ยอมคืนนาฬิกาให้นายแดงไป และนายแดงบอกว่าจะไม่เอาโทษนายสังข์และมอบนาฬิกาให้นายสังข์ไป ก็มีได้ทำให้ความผิดฐานลักทรัพย์ ซึ่งทำสำเร็จไปแล้ว กลายเป็นไม่เป็นความผิดไม่ได้

ดังนั้น นายสังข์จึงมีความผิดฐานลักทรัพย์

นายสังข์ได้บอกกับนายแดงว่า ตนได้บอกกับนายหมึกไว้ว่าจะนำนาฬิกาที่ลักได้ไปขายให้นายหมึกในราคาถูก เพราะเห็นว่านายหมึกไม่เคยมีนาฬิกาใช้เลยในชีวิต นายแดงไม่เอาโทษนายสังข์ และมอบนาฬิกาเรือนนั้นให้นายสังข์ไปขายให้นายหมึก นายหมึกรู้เรื่องการที่นายสังข์ไปลักนาฬิกาของนายแดง แต่ด้วยความอยากได้จึงรับซื้อไว้ในราคาถูก

ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 357) บัญญัติว่า “ผู้ใดช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งทรัพย์สินอันได้มาโดยการกระทำความผิด ถ้าความผิดนั้นเข้าลักษณะลักทรัพย์... ผู้นั้นกระทำความผิดฐานรับของโจร ต้องระวางโทษ...”

จากข้อเท็จจริงตามปัญหา แม้นายหมึกจะเข้าใจว่านาฬิกาที่ตนซื้อจากนายสังข์เป็นนาฬิกาที่นายสังข์ไปลักมาจากนายแดง แต่ด้วยความอยากได้จึงรับไว้ นายหมึกก็ไม่มี ความผิดฐานรับของโจร เพราะข้อเท็จจริง

นาฬิกาที่นายหมึกรับซื้อไว้ไม่ได้เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการลักทรัพย์แต่อย่างใด แต่เป็นทรัพย์สินที่นายแดงเจ้าของมอบให้นายสังข์โดยสมัครใจ เพื่อให้ให้นายสังข์นำมาขายให้นายหมึก

ดังนั้น นายหมึกจึงไม่มีความผิดฐานรับของโจร ตามหลักกฎหมายดังกล่าวมาข้างต้น

วิเคราะห์

สำหรับข้อสอบข้อนี้ไม่ยากเลย เพราะนักศึกษาจับประเด็นถูกทุกคน คือรู้ว่าเป็นความผิดฐานลักทรัพย์กับรับของโจร ดังนั้น นักศึกษาที่ยกหลักกฎหมายมาตรา 334 เรื่องลักทรัพย์ และ มาตรา 357 เรื่องรับของโจร นักศึกษาก็จะตัดคะแนนหลักกฎหมายไปแล้ว

แต่ความยากของข้อสอบข้อนี้อยู่ตรงที่ว่า

1. **ในความผิดฐานลักทรัพย์** เมื่อโจทก์บอกว่านายแดงเจ้าของทรัพย์สินจับได้ นายสังข์ได้สารภาพผิดและยอมคืนนาฬิกาให้นายแดงไป ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนว่าความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จแล้ว นายสังข์ได้ทรัพย์สินไปแล้ว นายแดงจึงมาจับได้ภายหลังและมาคืนนาฬิกาให้ภายหลัง แต่นักศึกษากลับไปตอบว่านายสังข์ไม่ผิดลักทรัพย์บ้าง เพราะคืนนาฬิกาให้นายแดงแล้ว หรือตอบว่านายสังข์ผิดฐานพยายามลักทรัพย์บ้าง ทั้ง ๆ ที่ความผิดฐานลักทรัพย์สำเร็จไปแล้ว บางคนก็ตอบว่าผิดลักทรัพย์แต่ไม่ต้องรับโทษเพราะคืนนาฬิกาให้นายแดงไป ทั้ง ๆ ที่การคืนนาฬิกาให้นี้ไม่เป็นเหตุยกเว้นโทษแต่อย่างใด

2. **ในความผิดฐานรับของโจร** โจทก์ได้บอกชัดเจนว่านายแดงได้ให้นาฬิกาเรือนนั้นแก่นายสังข์เพื่อให้ขายไปขายให้นายหมึกในราคาถูก ๆ ตามที่ตั้งใจ ดังนั้น นาฬิกาเรือนที่นายสังข์นำไปขายให้นายหมึกก็ไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด นายหมึกรับซื้อไว้จึงไม่มีความผิดฐานรับของโจร พูดย่าง ๆ ก็คือ นาฬิกาเรือนนั้นไม่ได้เป็นของโจร ผู้รับไว้จะผิดฐานรับของโจรได้อย่างไร แต่นักศึกษาก็ตอบว่าผิดฐานรับของโจรกันส่วนมาก เพราะไปหลงกับโจทก์ที่บอกว่านายหมึกรู้เรื่องการที่นายสังข์ไปลักนาฬิกาจากนายแดง แต่ด้วยการอยากได้จึงรับซื้อไว้ ทั้ง ๆ ที่เป็นเพียงความเข้าใจของนายหมึกเพียงผู้เดียว การวินิจฉัยกฎหมายต้องดูตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นว่าทรัพย์สินนั้นเป็นของโจรหรือไม่ มิใช่ดูตามความเข้าใจของผู้กระทำ อาจารย์ขอยกตัวอย่าง เช่น ฟ้าต้องการลักสร้อยคอของเหลียงในตอนกลางคืน แต่สร้อยคอของเหลียงวางอยู่ใกล้สร้อยคอของฟ้า ด้วยความมืดฟ้าจึงหยิบสร้อยคอของตนเองไป โดยเข้าใจว่าเป็นสร้อยคอของเหลียง ดังนี้ จะบอกว่าฟ้าผิดฐานลักทรัพย์เพราะฟ้าผู้กระทำเข้าใจว่าสร้อยที่ตนลักเป็นของเหลียงไม่ได้ เราต้องดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น มิใช่ดูเพียงความเข้าใจของผู้กระทำ กรณีนี้ฟ้าเอาทรัพย์สินของตนเองไปจึงไม่มีความผิดฐานลักทรัพย์แต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี นักศึกษาต้องจำหลักไว้อย่างหนึ่งว่าความผิดอาญานั้นเป็นความผิดสำเร็จไปแล้ว ก็จะเป็นความผิด การที่ผู้เสียหายให้อภัยก็ดี การที่ผู้กระทำผิดเอาทรัพย์สินกลับไปคืนก็ดี มิได้ทำให้ความผิดฐานลักทรัพย์ที่สำเร็จไปแล้ว กลายเป็นไม่สำเร็จไปได้ ส่วนจะมีเหตุบรรเทาโทษอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ในการสอบครั้งต่อไป ขอให้นักศึกษาอ่านหนังสือให้มากขึ้น เวลาตอบให้ยกหลักกฎหมายขึ้นก่อน แล้ววินิจฉัยปรับบทแล้วจึงสรุปธงคำตอบให้ชัดเจน ขอให้นักศึกษาโชคดีในการสอบครั้งต่อไปนะคะ



กฎหมายพาณิชย์ 3 : ประกันด้วยบุคคล และทรัพย์สิน ตัวเงิน

รองศาสตราจารย์ เพชรา จารุสกุล

คำถาม

นายอาทิตย์ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไม่ได้กรอกข้อความ หลังจากนั้นนายอังการมารอกข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวว่า นายอาทิตย์มอบอำนาจให้ตนเป็นผู้มีอำนาจในการยื่นคำขอจดทะเบียนขายที่ดินมีโฉนดของนายอาทิตย์แปลงหนึ่งให้แก่ตนเอง ซึ่งข้อเท็จจริงนายอาทิตย์มิได้รู้เห็นยินยอม ต่อมา นายอังการได้ไปจดทะเบียนขายที่ดินนั้นให้แก่ตนเองแล้ว หลังจากนั้นได้นำที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองไว้แก่นางเพ็ญจันทร์ เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินของนายอังการ จำนวน 100,000 บาท ข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางเพ็ญจันทร์ได้จดทะเบียนจำนองที่ดินนั้นไว้โดยรู้ว่ นายอังการไม่มีอำนาจนำที่ดินดังกล่าวมาจำนอง ต่อมา นายอังการผิดนัดชำระหนี้ นางเพ็ญจันทร์จะบังคับจำนองที่ดินนั้น แต่นายอาทิตย์คัดค้านว่าสัญญาจำนองไม่มีผลผูกพัน นางเพ็ญจันทร์อ้างว่า สัญญาจำนองที่ดินนั้นมีผลผูกพัน เนื่องจากนายอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินกระทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ให้วินิจฉัยว่า ข้ออ้างของนางเพ็ญจันทร์ฟังขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ยกหลักตาม ป.พ.พ. มาตรา 705 บัญญัติว่า "การจำนองทรัพย์สินนั้น นอกจากผู้เป็นเจ้าของในขณะนั้นแล้ว ท่านว่าใครอื่นจะจำนองหาได้ไม่"

วินิจฉัยตามปัญหา นายอาทิตย์ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไม่ได้กรอกข้อความ ดังนั้นจึงไม่มีการมอบอำนาจให้ใครกระทำการใด หลังจากนั้นนายอังการมารอกข้อความลงในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวว่า นายอาทิตย์มอบอำนาจให้ตนเป็นผู้มีอำนาจในการยื่นคำขอจดทะเบียนขายที่ดินมีโฉนดของนายอาทิตย์แปลงหนึ่งให้แก่ตนเอง โดยนายอาทิตย์มิได้รู้เห็นยินยอม ต่อมา นายอังการได้ไปจดทะเบียนขายที่ดินนั้นให้แก่ตนเองแล้ว หลังจากนั้นได้นำที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองไว้แก่นางเพ็ญจันทร์ เพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินของนายอังการ จำนวน 100,000 บาท เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า นางเพ็ญจันทร์รับจดทะเบียนจำนองที่ดินนั้นไว้โดยรู้ว่ นายอังการไม่มีอำนาจนำที่ดินดังกล่าวมาจำนอง เช่นนี้เป็นกรณีที่ดินนางเพ็ญจันทร์ผู้รับจำนองได้รับจำนองที่ดินนั้นไว้โดยไม่สุจริต นิติกรรมการโอนที่ดินดังกล่าวมาเป็นของนายอังการจึงตกเป็นโมฆะ นายอังการไม่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินนั้น จึงไม่มีสิทธิเอาที่ดินนั้นไปจำนองนางเพ็ญจันทร์ สัญญาจำนองดังกล่าวจึงไม่มีผลผูกพันนายอาทิตย์ เพราะการจำนองทรัพย์สินนั้นนอกจากผู้เป็นเจ้าของในขณะนั้นแล้ว ท่านว่าใครอื่นจะจำนองหาได้ไม่ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 705

แต่ต่อมานายอึ้งการผิดนัดการชำระหนี้ นางเพ็ญจันทร์ก็ไม่อาจบังคับจำนองที่ดินดังกล่าวโดยอ้างว่าสัญญาจำนองที่ดินนั้นมีผลผูกพัน เนื่องจากนายอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินกระทำการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

วิเคราะห์

1. ข้อนี้เป็นเรื่องการนำทรัพย์สินมาจำนองเป็นประกันหนี้ ผู้มีสิทธินำทรัพย์สินมาจำนองนั้นจะต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้น คนอื่นไม่มีสิทธิดังกล่าว (มาตรา 705)

ลำดับแรกต้องวินิจฉัยก่อนว่านายอาทิตย์ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไม่ได้กรอกข้อความไว้ นั้น **ไม่เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง** เพราะนายอาทิตย์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายอึ้งการกระทำการใดเลย เพราะข้อเท็จจริงมีว่านายอาทิตย์มิได้รู้เห็นยินยอมในการที่นายอึ้งการนำใบมอบอำนาจไปกรอกข้อความขายที่ดินให้ตนเอง นิติกรรมจึงเป็นโมฆะ หลังจากนั้นนำที่ดินดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองไว้แก่นางเพ็ญจันทร์ เพื่อเป็นการประกันการกู้ยืมเงินของนายอึ้งการ โดยนางเพ็ญจันทร์รู้ว่านายอึ้งการไม่ใช่เจ้าของที่ดินดังกล่าว

ลำดับที่สอง ต้องวินิจฉัยว่าการจำนองนั้นมีผลอย่างไรหรือไม่ เมื่อนายอึ้งการไม่ใช่เจ้าของทรัพย์สินที่นำมาจำนองในขณะนั้น สัญญาจำนองก็ไม่มีผลผูกพันนายอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่แท้จริง

นักศึกษาส่วนใหญ่ (90%) ตอบโดยไม่วิเคราะห์ก่อนว่ามีการมอบอำนาจกันหรือไม่ โดยตอบว่านายอาทิตย์ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจโดยไม่ได้กรอกข้อความใด เป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยไม่ได้ดูข้อเท็จจริงในโจทย์ที่ให้มาว่านายอาทิตย์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายอึ้งการทำการใดเลย

2. เมื่อวินิจฉัยว่านายอึ้งการมีอำนาจทำนิติกรรมซื้อขาย วินิจฉัยต่อไปว่านายอึ้งการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงมีอำนาจนำไปจำนองแก่นางเพ็ญจันทร์ ซึ่งการผิดพลาดเป็นผลมาจากการไม่ได้วินิจฉัยข้อ 1

3. เรื่องการบังคับจำนอง นักศึกษาวินิจฉัยว่าข้ออ้างของนางเพ็ญจันทร์ฟังไม่ขึ้น เพราะนางเพ็ญจันทร์รู้ว่าที่ดินที่นายอึ้งการนำมาจดทะเบียนจำนองได้มาอย่างไร เป็นการทุจริตในการทำสัญญาโดยไม่ได้ยกเหตุผลที่ว่าที่ดินนางเพ็ญจันทร์บังคับจำนองไม่ได้นั้นเพราะนายอึ้งการไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่นำมาจำนอง ประเด็นเรื่องนี้ นักศึกษากว่า 80% ตอบเหตุผลในการบังคับจำนองไม่ถูกต้อง โดยวินิจฉัยไปตามหลักตรรกะว่าเมื่อนางเพ็ญจันทร์รู้ความเป็นมาของการได้ที่ดินจึงเป็นการทุจริต

4. นักศึกษาส่วนหนึ่งไปตอบเรื่องการจำนองต้องมีการทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อได้ทำตามแบบดังกล่าวแล้วก็สามารถบังคับจำนองได้ โดยไม่ได้วินิจฉัยก่อนว่าคนที่นำที่ดินมาจำนองนั้นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม่ ข้อนี้จึงไม่ได้คะแนนตามที่ควร

5. นักศึกษาบางส่วนก็ไปโยงเรื่องคำประกันตามมาตรา 681 วรรค 1 มาตอบว่าคำประกันต้องเกิดจากหนี้ประจักษ์ที่สมบูรณ์ ซึ่งกฎหมายให้นำเรื่องคำประกันมาใช้ในเรื่องจำนองด้วย แสดงว่าเอาคำตอบของข้อสอบข้อ 1 มาใช้ตอบปัญหาข้อ 2 ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะกรณีนี้ไม่ใช่เรื่องหนี้ประจักษ์ที่สมบูรณ์ เป็นเรื่องที่ผู้จำนองไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่นำมาจำนองจึงจำนองไม่ได้



กฎหมายพาณิชย์ 4 : หุ่นส่วน บริษัท

รองศาสตราจารย์ ศิริศักดิ์ ศุภมนตรี

คำถาม

หลังจากที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัทหมื่นวรรณ จำกัด ซึ่งทำการค้าอัญมณี นายโยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมจัดตั้งบริษัทในกิจการที่นายโยได้ไปจ้างนายกองให้มาทำการตกแต่งสำนักงานบริษัทหมื่นวรรณ จำกัด เป็นเงิน 250,000 บาท หลังจากการประชุมจัดตั้งได้เพียงสัปดาห์เดียว นายกองเรียกให้นายโยชำระหนี้ค่าตกแต่งบริษัท นายโยปฏิเสธการชำระหนี้ต่อนายกอง โดยแจ้งให้นายกองไปเรียกค่าตกแต่งจำนวน 250,000 บาท นั้น จากบริษัทหมื่นวรรณ จำกัด เพราะที่ประชุมจัดตั้งบริษัทนั้น ได้อนุมัติการว่าจ้างดังกล่าวแล้ว นายกองโต้แย้งว่าบริษัทหมื่นวรรณ จำกัดนั้น ยังจดทะเบียนบริษัทไม่เรียบร้อย ตนจะไปเรียกจากบริษัทได้อย่างไร นายโยจะต้องชำระหนี้ให้นายกองจำนวน 250,000 บาท จะปฏิเสธไม่ได้

ให้ท่านวินิจฉัยว่านายโยสามารถปฏิเสธการชำระหนี้ค่าตกแต่งที่นายกองมาเรียกให้ชำระได้หรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวตอบ

ตามพพ.มาตรา 1113 บัญญัติว่า ผู้เริ่มก่อการบริษัทต้องรับผิดชอบร่วมกันและโดยไม่จำกัดในบรรดาหนี้ และการจ่ายเงินซึ่งที่ประชุมตั้งบริษัทมีได้อนุมัติ และแม้จะอนุมัติก็ยังต้องรับผิดชอบอยู่เช่นนั้นไปจนกว่าจะได้จดทะเบียนบริษัท

จากปัญหา นายโยซึ่งเป็นผู้ก่อการคนหนึ่งในการจัดตั้งบริษัทหมื่นวรรณ จำกัด ได้ไปจ้างนายกองมาตกแต่งสำนักงาน และในการประชุมจัดตั้งบริษัทที่ประชุมได้อนุมัติค่าใช้จ่ายดังกล่าว แต่บริษัทหมื่นวรรณยังจดทะเบียนจัดตั้งไม่เป็นที่เรียบร้อย จึงยังไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล นายโยในฐานะที่เป็นผู้เริ่มก่อการที่ได้รับอนุมัติในกิจการดังกล่าวจากที่ประชุมจัดตั้งแล้วก็ตาม แต่ตามพพ.มาตรา 1113 กำหนดว่าแม้ที่ประชุมจะอนุมัติบรรดาหนี้หรือการจ่ายเงินแล้วก็ตามแต่ตราบได้ที่บริษัทยังจดทะเบียนไม่เรียบร้อย ผู้เริ่มก่อการยังคงต้องรับผิดชอบ ดังนั้นการที่นายโยปฏิเสธให้นายกองไปเรียกจากบริษัทเพราะที่ประชุมอนุมัติแล้วนั้น ข้อโต้แย้งของนายกองที่ว่าบริษัทยังไม่ได้จัดตั้งเป็นที่เรียบร้อยนั้นเป็นเหตุผลที่ถูกต้อง และผู้ที่ยังต้องรับผิดชอบในหนี้ดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดก็ยิ่งเป็นนายโยผู้เริ่มก่อการยังต้องร่วมรับผิดชอบจนกว่าบริษัทจะจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย

นายโยจึงไม่สามารถที่จะปฏิเสธหนี้ค่าตกแต่งที่นายกองมาเรียกเก็บจำนวน 250,000 บาท ได้แต่อย่างใด

วิเคราะห์

จากปัญหาข้อนี้สิ่งที่พบจากนักศึกษาคือการที่ไม่ชัดเจนในหลักกฎหมาย และการวิเคราะห์ในเรื่องโครงสร้างขององค์การธุรกิจ ซึ่งพอที่จะแยกชี้แจงในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

1. กรณีโครงสร้างขององค์การธุรกิจว่าเป็นรูปแบบใด และการใช้ถ้อยคำของกฎหมายให้ตรงตามลักษณะของประเภทธุรกิจ ดังนั้นสิ่งที่พบก็คือนักศึกษาไม่วิเคราะห์ก่อนว่าเป็นเรื่องของบริษัท บางคนยังตอบว่าเป็นห้างหุ้นส่วนซึ่งทำให้หลักเกณฑ์และสาระที่นำมาตอบก็จะผิดพลาดไป และบางคนก็ตอบว่าเป็นบริษัทแต่ใช้คำว่าผู้ถือหุ้นส่วนซึ่งเมื่อเป็นบริษัทบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนก็จะเรียกว่าผู้ถือหุ้นและผู้เริ่มก่อการก็จะใช้คำว่าผู้ถือหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน จึงทำให้ลักษณะของการตอบข้อสอบขาดความชัดเจน สิ่งนี้เป็นสาระที่สำคัญที่นักศึกษาต้องพึงระวังในการแยกลักษณะขององค์การธุรกิจและการใช้ถ้อยคำของบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นให้ถูกต้อง มิฉะนั้นความหมายจะคลาดเคลื่อนไปทำให้คะแนนเสียไม่ได้

2. กรณีที่พบในเรื่องของผู้เริ่มก่อการนั้น พบว่านักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ไปเอาข้อสันนิษฐานในเรื่องของห้างหุ้นส่วนจำกัดมาใช้ คือตราบไต่ที่ยังไม่จดทะเบียนให้ถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนที่หุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบโดยไม่จำกัด ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องขององค์การธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด แต่กรณีนี้เป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีข้อกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำการล่วงหน้าของผู้เริ่มก่อการไว้อย่างชัดเจน

3. สำหรับนักศึกษาที่ตอบประเด็นที่ถามค่อนข้างใกล้เคียงแต่ไม่ตรงประเด็นนัก ก็คือตอบในประเด็นที่ว่าเมื่อบริษัทยังไม่จดทะเบียน บริษัทก็ยังไม่ต้องรับผิดชอบ เมื่อถึงเวลาที่ประเด็นนี้ แม้จะถูกต้องในส่วนของข้อความตอบก็ตาม แต่คะแนนก็จะไม่ได้มากเท่าที่ควร เพราะประเด็นที่ถูกต้องในกรณีนี้ถามว่า อยู่ที่ว่า กิจการที่ผู้เริ่มก่อการได้กระทำไปแล้วและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นแล้วก็ตาม ผู้เริ่มก่อการก็ยังคงต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สินนั้นอยู่จนกว่าบริษัทจะจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นประเด็นของการตอบจึงอยู่ที่ว่า แม้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติกิจการนั้นแล้วก็ตาม ผู้เริ่มก่อการก็ยังคงต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ก่อนที่บริษัทจะจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย หากบริษัทจดทะเบียนแล้วเจ้าหนี้มาเรียกให้ชำระหนี้แทนนี้จึงจะสามารถที่จะปฏิเสธให้ไปเรียกจากบริษัทได้

จากปัญหาที่พบจากการตรวจสอบดังกล่าวจึงฝากข้อคิดมายังนักศึกษาว่า กรณีที่สำคัญที่สุดจึงต้องพยายามแยกแยะลักษณะขององค์การธุรกิจให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนทำอ่านหนังสือ เพราะกฎหมายที่ใช้ในแต่ละประเภทของธุรกิจนั้นใกล้เคียงกัน ทำให้นักศึกษานำมาใช้คลาดเคลื่อนได้ อีกประการหนึ่งก็คือการวิเคราะห์โจทย์และการตอบต้องให้ตรงประเด็นและชัดเจนว่าหลักนั้นอยู่ในส่วนใด เช่นเรื่องนี้อยู่ที่ แม้จะอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนจึงยังต้องรับผิดชอบ มีใช้ตอบเฉพาะประเด็นที่ว่าบริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนจึงเรียกหนี้จากบริษัทไม่ได้ สุดท้ายฝากในหลักการว่าอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์โจทย์ให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยลงมือตอบให้ตรงและจับประเด็นให้ชัดเจนตอบให้ตรงประเด็น คะแนนเต็มก็จะรอนักศึกษาอยู่



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

อาจารย์ พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล

ข้อ 1

นายหนึ่งฟ้องนายสองให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ส่งหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องให้นายสองไม่ได้ เพราะนายสองถึงแก่ความตายไปก่อนถูกฟ้อง โดยนายหนึ่งเพิ่งทราบจากรายงานการส่งหมายของเจ้าพนักงานศาล นายหนึ่งจึงขอให้ศาลหมายเรียกนายสามทายาทของนายสองแต่ไม่มีสิทธิได้รับมรดกของนายสองเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่นายสองผู้มรณะ โดยยื่นคำขอตั้งกล่าวภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่นายสองถึงแก่ความตาย ศาลมีคำสั่งให้หมายเรียกนายสามเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่นายสองผู้มรณะ

ให้วินิจฉัยว่า คำสั่งของศาลชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ป.วิ.พ. มาตรา 42 บัญญัติว่า "ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลได้มรณะเสียก่อนศาลพิพากษาคดี ให้ศาลเลื่อนการนั่งพิจารณาไปจนกว่าทายาทของผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของผู้มรณะ หรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์สินมรดกไว้ จะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะ โดยมีคำขอเข้ามาเอง หรือโดยที่ศาลหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจากคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอฝ่ายเดียว คำขอเช่นว่านี้จะต้องยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะ

ถ้าไม่มีคำขอของบุคคลดังกล่าวมาแล้ว หรือไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเรื่องนั้นเสียจากสารบบความ"

วินิจฉัย

คำสั่งของศาลไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้นายสามทายาทของนายสองซึ่งไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดก แต่สามารถเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ได้ และนายหนึ่งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกนายสามเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่นายสองถึงแก่ความตายก็ตาม แต่นายสองได้ถึงแก่ความตายไปก่อนที่จะถูกนายหนึ่งฟ้อง กรณีจึงมิใช่เรื่องคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลได้มรณะเสียก่อนศาลพิพากษาตามบทบัญญัติมาตรา 42 นายหนึ่งจึงไม่สามารถฟ้องนายสองตามมาตรา 55 และขอให้ศาลหมายเรียกนายสามทายาทของนายสองเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่นายสองผู้มรณะได้

วิเคราะห์

จากคำถามมีประเด็นที่ต้องพิจารณาสองประเด็น

ประเด็นที่ 1 นายสามเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่นายสองได้หรือไม่ สำหรับประเด็นนี้แม้นายสามทายาทของนายสองซึ่งไม่มีสิทธิได้รับทรัพย์สินมรดก นายสามก็สามารถเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ได้ โดยนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 365/2509

ประเด็นที่ 2 คำสั่งของศาลให้หมายเรียกนายสามเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่นายสองผู้มรณะ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การที่ศาลมีคำสั่งให้หมายเรียกนายสามเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้มรณะหรือนายสองนั้น เป็นการกระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากขัดกับหลักกฎหมายตาม ป.วิ.พ. มาตรา 42 เหตุผลที่สำคัญก็เนื่องมาจาก การจะเรียกบุคคลเข้ามาแทนที่ผู้มรณะตามมาตรา 42 นั้น จะเป็นคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล แต่จากโจทก์ที่ให้มา นายสองถึงแก่ความตายไปก่อนที่นายหนึ่งจะฟ้อง เพราะฉะนั้น กรณีดังกล่าวศาลจึงไม่สามารถมีหมายเรียกนายสามให้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ได้ นอกจากนั้น เนื่องจากความตายของนายสอง ทำให้การฟ้องคดีของนายหนึ่งเป็นการฟ้องผู้มรณะ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการฟ้องคนตายซึ่งไม่มีสภาพบุคคล ซึ่งไม่สามารถฟ้องได้ตามหลักกฎหมายในมาตรา 55 แห่ง ป.วิ.พ.

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. ข้อผิดพลาดที่พบมากที่สุด สำหรับข้อสอบข้อนี้คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ถูกโจทก์หลอก เนื่องจากโจทก์เน้นว่านายหนึ่งได้ยื่นคำขอภายในกำหนด 1 ปีนับตั้งแต่วันที่นายสองถึงแก่ความตาย ซึ่งเป็นไปตามหลักกฎหมายในมาตรา 42 แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ลืมไปว่า คดีที่จะนำมาตรา 42 มาปรับใช้ได้นั้น จะต้องเป็นคดีค้างพิจารณาอยู่ในศาล ดังนั้นเมื่อปรับหลักกฎหมายผิดพลาดไป คำตอบที่ได้ก็จะผิดจากธงคำตอบอย่างชัดเจน การวิเคราะห์ก็จะผิดพลาด ซึ่งชัดเจนมากจนไม่รู้อาจารย์จะให้คะแนนอย่างไร

2. ข้อผิดพลาดประการที่สองคือ นักศึกษาทราบว่ นายสองได้ถึงแก่ความตายไปก่อนถูกฟ้อง เนื่องจากความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน เลยไม่ตอบมาตรา 42 เลย ไปตอบมาตรา 55 อย่างเดียว คำถามที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ คำตอบถูกไหม คำตอบที่จะได้ก็คือ ไม่ถูก เพราะโจทก์ถามว่าคำสั่งของศาลที่มีหมายเรียกให้นายสามเข้ามาแทนที่ผู้มรณะนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การจะตอบข้อสอบให้ถูกต้องก็ต้องอ้างว่า คำสั่งศาลไม่ชอบเพราะไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายมาตรา 42 และสามารถอ้างเพื่อไขว้ความรู้ต่อไปได้ด้วยว่า การที่นายสองเป็นผู้มรณะก่อนที่ นายหนึ่งจะฟ้อง ขัดต่อหลักกฎหมายมาตรา 55 เพราะนายสองไม่มีสภาพบุคคลแล้ว นายหนึ่งจึงไม่สามารถฟ้องนายสองได้ ดังนั้น หากนักศึกษาท่านใดตอบเฉพาะมาตรา 55 มาตราเดียว อาจารย์ก็สามารถสรุปได้ว่า น่าเสียใจกับนักศึกษาท่านนั้นจริงๆ

3. ข้อผิดพลาดประการสุดท้ายที่พบเห็นพอสมควร คือ นักศึกษาจะอ้างหลักกฎหมายเรื่องการร้องสอดเข้ามาปรับใช้ ซึ่งแน่นอนมากกว่าผิดเต็มๆ ไม่ใช่อย่างนี้นักศึกษาเดาอย่างแน่อน เพราะเหตุใดคงไม่ต้องอธิบายกันแล้ว เนื่องจากที่ได้อธิบายมาในตอนวิเคราะห์กันมาเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น นักศึกษาที่อ้างเรื่องการร้องสอดมา อาจารย์ก็คงได้แต่บอกว่า อ้างผิดนะครับ หวังว่าส่วนปรนัยคงทำคะแนนได้ดีทีเดียว

ข้อ 3

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกู้เงินไปจากโจทก์จำนวน 50,000 บาท ตามหนังสือสัญญากู้ยืมฟ้อง จำเลยได้รับเงินไปจากโจทก์แล้ว ครบกำหนดจำเลยไม่ชำระเงินคืน ขอให้บังคับจำเลยชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยให้การว่าจำเลยชำระเงินกู้คืนให้แก่โจทก์ครบถ้วนแล้ว ขอให้ยกฟ้อง วันขึ้นสองสถานจำเลยแถลงต่อศาล ขอสละข้อต่อสู้ตามคำให้การ และคู่ความแถลงไม่ติดใจสืบพยาน ขอให้ศาลพิพากษาไปตามรูปคดี

ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตามฟ้องได้หรือไม่

แนวตอบ

หลักกฎหมาย

ตามหลัก ป.วิ.พ. มาตรา 84 บัญญัติว่า

“การวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีใดจะต้องกระทำโดยอาศัยพยานหลักฐาน ในสำนวนคดีนั้น เว้นแต่ ...

(3) ข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาล

วินิจฉัย

ตามคำให้การของจำเลย จำเลยไม่ได้ต่อสู้ว่าไม่ได้กู้เงินโจทก์ หนังสือสัญญากู้ยืมฟ้องปลอมหรือปฏิเสธรายละเอียดของสัญญาที่ว่าไม่ถูกต้องแต่อย่างใด ถือไม่ได้ว่าจำเลยปฏิเสธความถูกต้องแท้จริงของสัญญา กู้ที่โจทก์นำมาฟ้อง เมื่อจำเลยรับว่าได้กู้เงินตามสัญญากู้ยืมฟ้อง โจทก์จึงไม่ต้องนำสืบพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ และเมื่อจำเลยให้การต่อสู้ว่าชำระเงินคืนแก่โจทก์แล้ว แต่ต่อมาแถลงต่อศาลสละข้อต่อสู้ดังกล่าว ถือว่าจำเลยรับว่า ยังไม่ได้ชำระคืนโจทก์ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 84 (3) ดังนั้น ศาลต้องพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบชำระต้นเงิน พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตามฟ้องได้

วิเคราะห์

จากโจทก์ที่นำมา โจทก์ต้องการถามนักศึกษาแค่ประเด็นเดียวว่า ศาลจะพิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ตามฟ้องได้หรือไม่ ประเด็นเดียวเท่านั้นจริงๆที่โจทก์ต้องการ การตอบข้อสอบข้อนี้ค่อนข้างง่ายมาก โดยอ้างหลักกฎหมายตาม ป.วิ.พ. มาตรา 84 (3) ว่าการวินิจฉัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีจะกระทำโดยไม่ต้องอาศัยพยานหลักฐานในสำนวนคดีก็สามารถทำได้ หากข้อเท็จจริงนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันในศาลแล้ว

ข้อผิดพลาดของนักศึกษา

1. ข้อผิดพลาดซึ่งอาจารย์พอจะสันนิษฐานได้คือ นักศึกษาส่วนใหญ่ลืมมาตรา 84 นี้ นักศึกษาเลยตอบสะเปะสะปะ บ้างก็อ้างหลักความยุติธรรม บ้างก็อ้างว่าศาลมีอำนาจตัดสินโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้คดีถึงที่สุด อ้างโน่นอ้างนี่โดยไม่มีหลักกฎหมายประกอบ การที่นักศึกษาอ้างมั่วๆ หากเป็นเหตุให้นักศึกษา

ได้คะแนนเต็มและครบ ถ้าอ้างฎีกาพอมีสิทธิ์ แต่ถ้าอ้างผิดและแยบยล อาจารย์คงต้องสันนิษฐานว่านักศึกษาท่านนั้น ไม่ได้อ่านหนังสือมาอย่างแน่นนอน ตัวอย่างเช่น อ้างเรื่องความยุติธรรม อ้างว่าเพื่อให้คดีไม่รกราก อ้างว่าศาลมีอำนาจวินิจฉัยได้โดยชอบเพราะคู่ความยอมรับกันในวันที่สองสถาน ฯลฯ เป็นการอ้างขึ้นลอยๆ ไม่มีหลักกฎหมายประกอบ น่าจะเป็นการอ้างเพื่อเหตุแห่งความจำเป็นมากกว่า จำเป็นเพราะจำหลักกฎหมายไม่ได้ หรือจำเป็นที่จะต้องอ้างเพราะไม่รู้ว่าจะตอบอะไรดี อาจารย์ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องให้คะแนนตามเนื้อผ้าและครบ

2. นักศึกษาบางท่านอ้างว่า มาตรา 84/1 อ้างว่าผู้ใดกล่าวอ้าง ผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบ ดังนั้นในวันที่สองสถานจำเลยสละข้อต่อสู้ เท่ากับจำเลยยอมรับ โจทก์จึงไม่ต้องนำสืบ ศาลสามารถพิพากษาได้โดยชอบเลย การอ้างมาตรา 84/1 มา คล้ายๆกับว่านักศึกษาจะหมดถูกทาง แต่อย่าลืมว่า มาตรา 84/1 เป็นหลักทั่วไป หลักทั่วไปทุกหลักมีข้อยกเว้น และที่สำคัญแม้จำเลยจะสละข้อต่อสู้ แต่โจทก์ก็ยังมีหน้าที่นำสืบอยู่ หากข้อเท็จจริงนั้นคู่ความไม่ยอมรับหรือถือว่ารับกันในศาล

3. ข้อผิดพลาดประการสุดท้ายที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นคือ การเขียนตอบข้อสอบแบบไม่มีหลัก หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการบรรยายตามความรู้สึกนึกคิดในขณะนั้น ไม่มีการอ้างหลักกฎหมาย ไม่มีการวิเคราะห์ และไม่มีการสรุป นักศึกษาบางท่านตอบข้อสอบในลักษณะเรียงความ เรียงตามความเข้าใจของตนในแต่ละบรรทัดที่เขียน การเขียนเช่นนี้ไม่ใช่หลักในการเขียนตอบกฎหมาย ท่านอาจเขียนเรียงความในลักษณะเช่นนี้ตอบข้อสอบของสาขาวิชาอื่นๆได้ แต่สำหรับสาขาวิชานิติศาสตร์แล้ว ขอให้นักศึกษาพึงระลึกได้ไว้เสมอว่า การเขียนตอบข้อสอบเพื่อให้ได้คะแนนดีนั้น ควรจะเขียนแบบมีรูปแบบ กล่าวคือ มีการวางหลักกฎหมาย วิเคราะห์ และสรุป สุดท้ายนี้อาจารย์ขอความกรุณาให้นักศึกษาลองนำบทวิเคราะห์ดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับคำตอบข้อสอบของตนว่าท่านได้ทำถูกต้องเพียงไร มีสิ่งไหนที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้คะแนนที่ดีในชุดวิชาอื่นๆอีกหรือไม่ หากนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง อาจารย์ (ทุกท่าน) ยินดีที่จะให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนตลอดเวลาครับ ขอเพียงแต่ให้นักศึกษามีความตั้งใจจริงในการศึกษาเล่าเรียนก็เพียงพอแล้ว



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2 : วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

อาจารย์ ธนวัฒน์ เนติโพธิ์

คำถาม

ให้นักศึกษาอธิบายว่าคดีซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เพราะเป็นคดีมีทุนทรัพย์พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท นั้น มีข้อยกเว้นที่ทำให้สามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ อย่างไรบ้าง

แนวตอบ

มาตรา 224 ในคดีที่ราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นอุทธรณ์ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ห้ามมิให้ผู้พิพากษาชั้นต้นพิจารณา คดีนั้นในศาลชั้นต้นได้ทำความเห็นแย้งไว้หรือได้รับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้ หรือถ้าไม่มีความเห็นแย้งหรือ คำรับรองเช่นนั้นต้องได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาชั้นต้นหรืออธิบดีผู้พิพากษามาคน ผู้มีอำนาจ แล้วแต่กรณี

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งมิได้ให้บังคับในคดีเกี่ยวกับสิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัว และคดีฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ เว้นแต่ในคดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจาก อสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาทหรือไม่เกินจำนวน ที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา

การขอให้ผู้พิพากษาชั้นต้นพิจารณาในคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้ ให้ผู้อุทธรณ์ ยื่นคำร้องถึงผู้พิพากษานั้น พร้อมกับคำฟ้องอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้น เมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นนั้น ให้ศาลส่ง คำร้องพร้อมด้วยสำนวนความไปยังผู้พิพากษาดังกล่าวเพื่อพิจารณารับรอง

นักศึกษาจะเห็นว่าในคำอธิบายเกี่ยวกับมาตรา 224 นี้ ในเอกสารการสอนได้แยกไว้เป็น 2 เรื่องคือ

1. ข้อยกเว้นที่อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ (คำอธิบายหน้า 5-20 ถึง 5-22)

ให้สังเกตว่าข้อยกเว้นนั้น ใช้กับคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงมาแล้วแต่ต้น ซึ่งโดยหลักแล้วจะอุทธรณ์ไม่ได้เลย อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแล้วก็ตาม ก็อาจ มีการถ้อยเป็นข้อยกเว้นทำให้คดีนั้นสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ คือ

- ผู้พิพากษาชั้นต้นพิจารณา คดีนั้นในศาลชั้นต้นได้ทำความเห็นแย้งไว้
- ผู้พิพากษาชั้นต้นพิจารณา คดีนั้นในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุอันควรอุทธรณ์ได้

- ได้รับอนุญาตให้อุทธรณ์เป็นหนังสือจากอธิบดีผู้พิพากษาชั้นต้นหรืออธิบดีผู้พิพากษามาคนผู้มีอำนาจ แล้วแต่กรณี

2. คดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง (คำอธิบายหลัก 5-23 ถึง 5-30)

คดีเหล่านี้เป็นคดีที่สามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้เสมอ ไม่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่อย่างใดทั้งสิ้น (ต่างกับการนิยมนับเป็นข้อยกเว้นให้อุทธรณ์ดังกล่าวแล้วแต่ต้น) หรืออาจเรียกได้ว่า คดีเหล่านี้ไม่อยู่ภายในบังคับของมาตรา 224 เลยก็ได้ คือ

- คดีเกี่ยวกับสิทธิแห่งสภาพบุคคลหรือสิทธิในครอบครัว
- คดีฟ้องขอให้ปลดปล่อยทาสอื่นไม่ว่าจำแนกเป็นราคาเงินได้ (เว้นแต่ในคดีฟ้องขับไล่

บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาท หรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา)

ข้อสอบต้องการให้ตอบเฉพาะกรณีที่เป็นข้อยกเว้นที่อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้เท่านั้น ไม่ต้องการถามถึงคดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงแต่อย่างใด ฉะนั้น หากนักศึกษาตอบไม่ตรงคำถาม เช่นไปเอาคดีที่ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงมาตอบ เช่นนี้ ก็จะได้คะแนน

คำถาม

บริษัทดีใจ จำกัด ถูกศาลล้มละลายกลางสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เข้าไปรวบรวมทรัพย์สินของบริษัทผู้ล้มละลายแล้วพบว่านายกรุงเป็นหนี้บริษัทดีใจ จำกัด ผู้ล้มละลายตามสัญญากู้ยืมเงินจำนวน 100,000 บาท เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงมีหนังสือทวงหนี้ให้นายกรุงชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว นายกรุงเห็นว่าตนเป็นหนี้บริษัทดีใจ จำกัด จริง แต่ได้ชำระหนี้เงินกู้คืนเสร็จสิ้นไปก่อนที่บริษัทดีใจ จำกัด จะถูกฟ้องล้มละลาย นายกรุงจึงได้มีหนังสือปฏิเสธหนี้ไปยังศาลล้มละลายกลาง ต่อมาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่านายกรุงมิได้มีหนังสือปฏิเสธหนี้มายังตน จึงได้มีคำขอต่อศาลล้มละลายกลางให้มีคำบังคับให้นายกรุงชำระหนี้

ท่านเห็นว่าการยื่นคำขอดังกล่าวของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถูกต้องหรือไม่เพียง

แนวตอบ

ข้อสอบข้อนี้ ไม่ยาก แม้ข้อสอบจะยาว เพราะโจทย์ต้องการถามเฉพาะกรณีที่ผู้ถูกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทวงหนี้จะต้องดำเนินการตอบปฏิเสธไปที่ใด อย่างไร เท่านั้น เป็นกรณีคำถาม ตามมาตรา 110 ดังนี้

มาตรา 119 เมื่อปรากฏว่าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดชำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินแก่ลูกหนี้ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งความเป็นหนังสือไปยังบุคคลนั้นให้ชำระเงินหรือส่งมอบทรัพย์สินตามจำนวนที่ได้แจ้งไปและให้แจ้งไปด้วยว่าถ้าจะปฏิเสธ ให้แสดงเหตุผลประกอบข้อปฏิเสธเป็นหนังสือมายัง

ประเด็นคำถามคือการที่นายกรุง มีหนังสือปฏิเสธหนี้ไปยังศาลล้มละลายกลาง ถือว่าเป็นการปฏิเสธหนี้ที่ถูกต้องตามมาตรา 119 นี้หรือไม่

การปฏิเสธหนี้นั้นต้องทำตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ คือในครั้งแรกจะต้องปฏิเสธไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เท่านั้น ถ้าปฏิเสธเป็นหนังสือแต่ไปยื่นผิดที่ เช่น ไปยื่นต่อศาลเสียเลย ดังนี้ต้องถือว่ามิได้ปฏิเสธหนี้ (จากคำอธิบาย หน้า 12-33) และถือว่าผู้ร้อง(นายกรุง)เป็นหนี้กองทรัพย์สินของผู้ล้มละลายตามมาตรา 119 เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้ผู้ร้องชำระหนี้ จึงเป็นการถูกต้องแล้ว (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 678/2508 ประชุมใหญ่ ในคำอธิบายหน้า 12-33)



กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3 : วิธีพิจารณาความอาญา

อาจารย์ เอกพงศ์ คลังกรณ์

ข้อ 1

ร้อยตำรวจเอกชุมพรได้รับแจ้งว่านายประจวบเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติด จึงนำกำลังเจ้าพนักงานตำรวจไปแอบซุ่มห่างจากหน้าป้ายรถประจำทางที่นายประจวบยืนอยู่ประมาณ 10 เมตร ร้อยตำรวจเอกชุมพรให้นางระนองซึ่งเป็นสายลับไปซื้อยาเสพติดกับนายประจวบ จากนั้นนางระนองเอายาเสพติดที่สั่งซื้อได้กลับมามอบให้ ร้อยตำรวจเอกชุมพรจึงนำกำลังเข้าไปตรวจค้นตัวนายประจวบทันที โดยให้นายประจวบล้วงของในกระเป๋าทางแกงออกมา ผลการตรวจค้นพบยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่ง ร้อยตำรวจเอกชุมพรจึงจับกุมนายประจวบ เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

ให้วินิจฉัยว่า ร้อยตำรวจเอกชุมพรตรวจค้นนายประจวบโดยไม่มีหมายค้น เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้
มาตรา 93 ห้ามมิให้ทำการค้นบุคคลใดในที่สาธารณะสถาน เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้นในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด

ประมวลกฎหมายอาญา มีบทบัญญัติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 ในประมวลกฎหมายนี้

(3) "สาธารณะสถาน" หมายความว่า สถานที่ใดๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้

จากบทกฎหมายดังกล่าว หมายความว่า กฎหมายห้ามมิให้ค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะสถาน ซึ่งคำว่า "สาธารณะสถาน" หมายความว่า สถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ เช่น ถนนหลวง ถนนตามหมู่บ้าน ร้านอาหาร โรงมหรสพ หรือสถานบริการต่างๆ เป็นต้น แต่กฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นให้ค้นบุคคลในที่สาธารณะสถานได้ เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

1. เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด เช่น พกพาอาวุธปืนไปเพื่อจะใช้ฆ่าผู้อื่น หรือ

2. เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นได้สิ่งของมาโดยการกระทำความผิด เช่น มีสร้อยคอทองคำที่ได้มาจากการวิ่งราวทรัพย์ซุกซ่อนอยู่ในตัว หรือ

3. เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด เช่น อาวุธปืนเถื่อน ยาเสพติด

ตามคำถามจากข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ขณะที่ร้อยตำรวจเอกชุมพรเจ้าพนักงานตำรวจนำกำลังเข้าตรวจค้นตัวนายประจวบนั้น นายประจวบกำลังยืนอยู่หน้าป้ายรถประจำทาง ดังนี้ หน้าป้ายรถประจำทางที่นายประจวบยืนอยู่จึงเป็นสถานที่ใด ๆ ซึ่งประชาชนมีความชอบธรรมที่จะเข้าไปได้ อันเป็นสาธารณะสถาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (3) ทำให้เป็นที่สาธารณะไม่ ดังนั้น การตรวจค้นบุคคลบริเวณหน้าป้ายรถประจำทางซึ่งเป็นสาธารณะสถานจึงไม่จำเป็นต้องมีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล

การที่ร้อยตำรวจเอกชุมพรได้รับแจ้งว่านายประจวบเป็นผู้จำหน่ายยาเสพติด จึงนำกำลังเจ้าพนักงานตำรวจไปแอบซุ่มห่างจากหน้าป้ายรถประจำทางที่นายประจวบยืนอยู่ประมาณ 10 เมตร โดยร้อยตำรวจเอกชุมพรให้นางระนองซึ่งเป็นสายลับไปซื้อยาเสพติดกับนายประจวบ จากนั้นนางระนองเอายาเสพติดที่สั่งซื้อได้กลับมามอบให้ร้อยตำรวจเอกชุมพร ร้อยตำรวจเอกชุมพรย่อมมีเหตุอันควรสงสัยว่านายประจวบมียาเสพติดไว้ในครอบครองอันเป็นสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ในการนี้ดังกล่าวนี้ ร้อยตำรวจเอกชุมพรและเจ้าพนักงานตำรวจจึงมีอำนาจตรวจค้นตัวนายประจวบที่หน้าป้ายรถประจำทางซึ่งเป็นสาธารณะสถานได้ อันเป็นกรณีที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93

ดังนั้น ร้อยตำรวจเอกชุมพรตรวจค้นนายประจวบโดยไม่มีความหมายค้น เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นเจ้าพนักงานตำรวจทำการค้นบุคคลในที่สาธารณะสถาน โดยมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นมีสิ่งของซึ่งมีไว้เป็นความผิด

วิเคราะห์

คำถามข้อนี้มีประเด็นสำคัญเพียงประเด็นเดียว คือ ร้อยตำรวจเอกชุมพรตรวจค้นนายประจวบหน้าป้ายรถประจำทางโดยไม่มีความหมายค้น เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดยมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาดังนี้

ประการแรก ประเด็นคำถามเรื่อง ร้อยตำรวจเอกชุมพรตรวจค้นนายประจวบหน้าป้ายรถประจำทางโดยไม่มีความหมายค้น เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นักศึกษาคควรอธิบายว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 บัญญัติห้ามมิให้ค้นตัวบุคคลในที่สาธารณะสถาน แต่กฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นให้ค้นบุคคลในที่สาธารณะสถานได้ เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และมีเหตุอันควรสงสัยว่า บุคคลนั้นมีสิ่งของในความครอบครองเพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรือซึ่งได้มาโดยการกระทำความผิดหรือซึ่งมีไว้เป็นความผิด ดังนั้น ร้อยตำรวจเอกชุมพรตรวจค้นนายประจวบหน้าป้ายรถประจำทางซึ่งเป็นสาธารณะสถานโดยไม่มีความหมายค้น เป็นการกระทำที่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93

ประการที่สอง มีนักศึกษาจำนวนมากที่ไม่อ่านคำถามให้ถี่ถ้วน ซึ่งข้อสอบถามเรื่องการค้น แต่ไปตอบเรื่องการจับ อันเป็นการตอบที่ไม่ตรงกับคำถาม ย่อมไม่ได้คะแนนในประเด็นสำคัญ

ประการที่สาม มีนักศึกษาบางคนเจ้าหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เรื่องการค้นไม่ได้ จึงวินิจฉัยว่าการค้นบุคคลในที่สาธารณะต้องมีหมายค้น ซึ่งเป็นการสับสนระหว่างการค้นในที่สาธารณะกับการค้นในที่สาธารณะ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 93 เป็นมาตราที่ต้องการทดสอบความรู้ของนักศึกษาในเรื่อง การค้นบุคคลในที่สาธารณะ อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับปริญญาตรีและในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น นักศึกษาจึงควรทำความเข้าใจในสาระสำคัญของเรื่องการค้น เพื่อสามารถอธิบายและวินิจฉัยได้ถูกต้อง ทั้งนักศึกษาควรทำกิจกรรมท้ายเรื่องและแบบฝึกหัดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถจับประเด็นปัญหาได้ถูกต้องว่าคำถามต้องการถามในเรื่องใด



กฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ภาณุศิลปกุล

คำถาม

1. นักศึกษาจงอธิบายหลักกฎหมายระหว่างประเทศแถมภาคดีเมือง (หน่วยที่ 1- 11) ที่นักศึกษา มีความรู้มากที่สุดเพียง 1 เรื่อง โดยละเอียด

แนวตอบ

(นักศึกษาสามารถตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักศึกษามีความรู้มากที่สุดมาเพียง 1 เรื่อง ของหน่วย ที่ 1-11)

ตัวอย่างคำตอบ ข้อ 1

ข้อ 1. กระบวนการทำสนธิสัญญา

หลักการเบื้องต้นในการทำสนธิสัญญา

การทำสนธิสัญญานั้นจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจในหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหลักการแห่งอำนาจอธิปไตยกับความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลเป็นการจำกัดอำนาจอธิปไตย บางส่วนของรัฐ เพื่อผูกพันรัฐตามสนธิสัญญา หลักการพื้นฐานที่สำคัญในการทำสนธิสัญญา ได้แก่ หลักการกระทำโดยสุจริต (*Good Faith* หรือ *Bona fide*) หลักการแสดงเจตนา หรือการแสดงเจตจำนงโดยอิสระ หรือการแสดงเจตนาโดยสมัครใจ (*Free Consent*) ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำสนธิสัญญา และ หลักการที่เป็นที่ยอมรับในทางระหว่างประเทศ เช่น หลักสัญญาต้องผูกพัน (*Pacta Sunt Servanda*) รัฐทุกรัฐในประชาคมระหว่างประเทศมีอำนาจอธิปไตยที่เท่าเทียมกันไม่ว่ารัฐเล็ก หรือรัฐใหญ่ การทำสนธิสัญญาจึงควรอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักการเช่นว่านี้ โดยที่รัฐทุกรัฐมีอำนาจในการทำสนธิสัญญาโดยอิสระ ตามเจตจำนงของรัฐนั้นๆ ไม่ตกอยู่ในอำนาจของรัฐใด

ตัวแทนรัฐในการทำสนธิสัญญา

อำนาจในการทำสนธิสัญญาของรัฐ จะกระทำผ่านตัวแทนของรัฐ ซึ่งตัวแทนของรัฐในการทำสนธิสัญญาอาจเป็นตัวแทนรัฐโดยตำแหน่ง หรือ ตัวแทนรัฐผู้มีอำนาจเต็ม

ตัวแทนรัฐโดยตำแหน่ง หรือ โดยมีอำนาจหน้าที่ (*Ex Officio*) ได้แก่

(ก) ประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในการดำเนินการใดๆ หรือการกระทำทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำสนธิสัญญา

(ข) หัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต มีอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับการยอมรับ หรือการรับเอา ข้อบทของสนธิสัญญาที่กระทำระหว่างรัฐผู้รับกับรัฐผู้ส่งทูตนั้น ซึ่งกรณีนี้ใช้สำหรับการทำสนธิสัญญาสองฝ่าย ระหว่างสองรัฐนั้นเท่านั้น

(ค) ผู้เป็นตัวแทนรัฐ เพื่อเข้าร่วมในการประชุมระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การใดขององค์การระหว่างประเทศ โดยมีอำนาจในส่วนที่เกี่ยวกับการยอมรับข้อบทของสนธิสัญญา ในการประชุมระหว่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ หรือองค์การขององค์การระหว่างประเทศนั้นๆ โดยผู้แทนเหล่านั้นได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ (accredited) ผู้แทนรัฐเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจเต็ม Full Powers (Art. 47 of Vienna Convention on the law of treaties 1969)

ตัวแทนรัฐผู้มีอำนาจเต็ม (Full Powers)

นอกจากนี้รัฐอาจจะแต่งตั้ง มอบอำนาจให้บุคคลใด หรือคณะบุคคลเป็นตัวแทนรัฐผู้มีอำนาจเต็มในการเจรจา ทำสนธิสัญญาได้โดยมีหนังสือมอบอำนาจเต็ม "Full Powers" ในการเจรจา (negotiation) ยอมรับ (Acceptance) รับรอง (Adoption) ข้อบทของสนธิสัญญา และในการแสดงเจตนาของรัฐในการที่รัฐจะผูกพันตามผลของสนธิสัญญา หรือเพื่อที่จะกระทำการใดๆ ให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญา

ความผูกพันของรัฐต่อผลของสนธิสัญญาที่รัฐได้กระทำขึ้น

รัฐภาคีไม่อาจปฏิเสธความผูกพันต่อสนธิสัญญาที่ตัวแทนได้กระทำแล้ว กล่าวคือ รัฐไม่อาจจะกล่าวอ้างความไม่สมบูรณ์ในการแต่งตั้งผู้แทนของรัฐนั้นซึ่งได้รับการแต่งตั้งมาโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายภายในของรัฐนั้นๆ มาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ผูกพันตามผลของสนธิสัญญาที่กระทำขึ้นโดยการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐโดยผู้แทนบุคคลนั้น เว้นแต่ความไม่สมบูรณ์เพราะการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภายในนั้นเป็นที่ทราบอย่างประจักษ์แจ้ง และการแต่งตั้งที่ไม่ชอบนั้นเป็นส่วนที่เกี่ยวกับกฎหมายภายในที่สำคัญอย่างยิ่งด้วย จึงเป็นสิ่งที่ภาคีของสนธิสัญญาพึงระมัดระวังอย่างยิ่งในการทำสนธิสัญญา

ขั้นตอนโดยสังเขปในการทำสนธิสัญญา

หลังจากที่รัฐภาคีได้เจรจา (Negotiation) ตกลง และยกร่าง (Draft) สนธิสัญญา ตลอดจนพิจารณาร่างสนธิสัญญา จนได้ข้อบทของสนธิสัญญาตามที่รัฐภาคีเห็นชอบแล้ว ภาคีทั้งหลายก็จะให้การรับรองร่างสนธิสัญญา (Adoption) ที่เรียกว่าเป็นการรับรองชั่วคราว และให้ความเห็นชอบรับรองความถูกต้องแท้จริงของข้อบทของสนธิสัญญา (Authentication) ตามที่ได้ตกลงกันนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการที่รัฐภาคีพร้อมที่จะแสดงความยินยอมผูกพันตามสนธิสัญญา (Expressing consent to be bound by the treaty) อันเป็นการรับรองขั้นสุดท้าย ซึ่งการให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญานั้นสามารถกระทำได้หลายวิธี ซึ่งวิธีที่ได้รับความนิยม และเป็นทางปฏิบัติของรัฐส่วนใหญ่ได้แก่การลงนาม (Signature) การแลกเปลี่ยนตราสาร (Exchange of instruments) การลงนามและการให้สัตยาบัน (Ratification) การยอมรับ (Acceptance) การให้ความเห็นชอบ (Approval) การภาคยานุวัติ (Accession) นอกจากนี้การให้ความยินยอมผูกพันตามสนธิสัญญาของภาคีของสนธิสัญญายังอาจจะกระทำได้โดยวิธีอื่นๆตามที่รัฐภาคีของสนธิสัญญาจะได้ตกลงกัน หรืออาจจะโดยวิธีอื่นใดตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ความสำคัญของการให้สัตยาบันสนธิสัญญา

การให้ความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการให้สัตยาบัน (Ratification) หลังจากการลงนามในสนธิสัญญาแล้ว มีความจำเป็นหลายประการ กล่าวคือหลังจากที่รัฐได้เจรจา ตกลง ในสาระสำคัญของสนธิสัญญาแล้ว และได้รับรองข้อบทในสนธิสัญญา ตลอดจนได้บรรลุข้อบทที่แน่นอนแล้ว (A definitive text) รัฐจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนก่อนที่จะให้ความยินยอมขั้นสุดท้ายผูกพัน รัฐต่อสนธิสัญญา หรือการรับรองขั้นสุดท้าย โดยมีเหตุผลดังต่อไปนี้

1. รัฐจะได้มีเวลาในการพิจารณาทบทวนทั้งในส่วนข้อบทในแต่ละมาตราซึ่งเป็น ข้อบทที่แน่นอนแล้วให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่ง และพิจารณาถึงผลโดยรวมของสนธิสัญญาต่อผลประโยชน์ ของประเทศชาติ
2. รัฐจะได้ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายในของรัฐให้ถูกต้อง เช่น ตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ การทำสนธิสัญญาชนิดที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสียก่อน ก็จะต้อง ดำเนินการไปตามนั้น ตลอดจนดำเนินการตามขั้นตอน กฎระเบียบ หรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหากมี เช่น ในบางกรณีหากเป็นสนธิสัญญาที่มีความสำคัญและการกระทบต่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยตรง รัฐอาจจะต้อง ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงประชามติ หรือการทำประชามติเพื่อประเมินในผลความผูกพัน ของรัฐตามสนธิสัญญานั้นๆ ต่อประโยชน์โดยรวมของประเทศชาติบ้านเมืองและมวลชน
3. รัฐอาจจะต้องดำเนินการเพื่อออกกฎหมายภายในมารองรับเพื่อให้การปฏิบัติตาม สนธิสัญญาเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือออกกฎหมายบังคับการให้เป็นไปตามสนธิสัญญานั้น หรือ ออกกฎหมายอนุวัติการตามสนธิสัญญา เป็นต้น

การให้สัตยาบันสนธิสัญญา

บทบาทของการให้สัตยาบันคือกระบวนการ หรือขั้นตอนที่กำหนดให้รัฐแสดงเจตนารมณ์ ให้ความยินยอมผูกพันรัฐตามสนธิสัญญา ดังนั้นหากในสนธิสัญญาใดที่มีการกำหนดให้ต้องมีการให้สัตยาบัน กันก่อน สนธิสัญญาจึงจะผูกพันรัฐนั้น หากรัฐภาคีใดยังไม่ได้ให้สัตยาบัน รัฐนั้นก็ยังไม่ต้องผูกพันตามสนธิสัญญา แม้ว่ารัฐนั้นจะได้ลงนามในสนธิสัญญาแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าสนธิสัญญานั้นไม่มีผลทางกฎหมายเลย การแสดงความยินยอมของรัฐเพื่อผูกพันตามสนธิสัญญาโดยการให้สัตยาบันนั้นต้องกระทำต่อเมื่อ

- (ก) สนธิสัญญานั้นกำหนดไว้ว่าการแสดงความยินยอมผูกพันตามสนธิสัญญาดังกล่าว ให้กระทำโดยการให้สัตยาบัน
- (ข) รัฐภาคีซึ่งเจรจาสนธิสัญญานั้นตกลงกันให้ต้องมีการให้สัตยาบัน
- (ค) ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจซึ่งได้ลงนามในสนธิสัญญานั้น จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ที่จะต้องมีการให้สัตยาบันโดยรัฐอีกครั้งหนึ่ง รัฐจึงจะผูกพันตามสนธิสัญญานั้น
- (ง) ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจเต็ม Full Powers ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของรัฐว่าการ ลงนามในสนธิสัญญาของตัวแทนนั้นจะต้องมีการให้สัตยาบันอีกครั้งหนึ่งรัฐจึงจะผูกพันตามสนธิสัญญา หรือ ในระหว่างที่มีการเจรจากันนั้น รัฐภาคีดังกล่าวได้แสดงเจตนาเช่นนั้น

ไม่สามารถกำหนดเงื่อนไขในการให้สัตยาบัน หรือการให้สัตยาบันบางส่วน

อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อบทของสนธิสัญญาในกระบวนการให้สัตยาบัน หมายความว่า ข้อบทของสนธิสัญญาที่ได้รับการรับรองแล้ว และยืนยันในความถูกต้องสมบูรณ์แล้วนั้น เป็นข้อบทที่แน่นอนแล้วของสนธิสัญญา จึงไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นเงื่อนไขในการให้สัตยาบัน การให้สัตยาบันจึงเป็นการยืนยันที่รัฐจะให้ความยินยอมที่จะผูกพันตามสนธิสัญญาที่ตกลงเช่นนั้นแล้ว ดังนั้น หากรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อรัฐ หรือรัฐจะเสียเปรียบก็เพียงแต่ไม่ให้สัตยาบันสนธิสัญญานั้นๆ ส่วนการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไขเพิ่มเติม นั้นจะดำเนินการไปตามที่ภาคีได้ตกลงกันในส่วน ของข้อกำหนดด้วย Amendment หรือ Modification ตามที่ตกลงในสนธิสัญญาต่อไปหรือเปิดการเจรจา กันใหม่ในส่วนนั้น ถ้าอีกฝ่าย หรือ ภาคีอื่นยินยอมเจรจาด้วย

รัฐผูกพันตามสนธิสัญญา

สนธิสัญญามีผลผูกพันรัฐนับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงนามในสนธิสัญญา ไม่ใช่ นับตั้งแต่ วันที่มีการให้สัตยาบันวันแต่ในสนธิสัญญา หรือโดยรัฐภาคีที่เข้าร่วมเจรจาจะได้กำหนด หรือ ตกลงกันเป็น อย่างอื่น ขอให้เข้าใจด้วยว่า การเริ่มมีผลบังคับของสนธิสัญญา (Entry into force) กับการที่รัฐผูกพันตาม สนธิสัญญา (to be bound by the treaty) เป็นคนละกรณีกัน

อำนาจในการให้สัตยาบัน

การให้สัตยาบันสนธิสัญญาเป็นอำนาจหน้าที่ของบุคคลผู้มีอำนาจในการทำสนธิสัญญา (Treaty-Making Power) กล่าวคือประมุขของรัฐ หรือ รัฐบาล จะต้องดำเนินการตามข้อกำหนดตามกฎหมาย เช่น หากเป็นสนธิสัญญาที่ต้องผ่านการอนุมัติ เห็นชอบ หรือผ่านการพิจารณาของสภา ก็ต้องดำเนินการ ตามนั้นให้ถูกต้องเสียก่อน จึงจะให้สัตยาบันได้ ดังนั้นการแสดงเจตนาให้สัตยาบันโดยไม่ผ่านกระบวนการ ดังกล่าวก็ทำให้การให้สัตยาบันไม่มีผลตามกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตระหนักให้ดี

ขอบเขตความผูกพันของสนธิสัญญาเหนือเขตแดนของรัฐ (Territorial Coverage of Treaty)

ความผูกพันตามสนธิสัญญาต่อรัฐนี้ เป็นความผูกพันที่มีอยู่เหนือดินแดนทั้งหมดของรัฐ

สนธิสัญญาไม่มีผลย้อนหลัง

หลักการที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ หลักการเรื่องสนธิสัญญาไม่มีผลย้อนหลัง (Non-Retroactivity of Treaty) ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปที่ใช้กับการกระทำทางกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวคือ เว้นแต่จะปรากฏเจตนาเป็นอย่างอื่นแตกต่างไปจากที่ปรากฏในสนธิสัญญา หรือปรากฏเป็นกรณีอย่างอื่น บทบัญญัติ ต่างๆของสนธิสัญญาย่อมไม่ผูกพันภาคีของสนธิสัญญาในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน วันที่สนธิสัญญามีผลใช้บังคับต่อภาคีของสนธิสัญญานั้น หรือสถานการณ์ซึ่งได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่สนธิสัญญามีผล

ความผูกพันของสนธิสัญญาตามกฎหมายภายในและข้อสงวน

สำหรับลักษณะความผูกพันของสนธิสัญญาตามกฎหมายภายในนั้น เมื่อสนธิสัญญามีผลใช้บังคับแล้ว รัฐภาคีจะต้องผูกพันตามบทบัญญัติของสนธิสัญญา และเนื่องจากการปฏิบัติตามพันธกรณีของสนธิสัญญานี้ครอบคลุมถึงองค์การต่างๆของรัฐทั้งหมดในฐานะที่องค์กรเหล่านี้ต้องทำหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามสนธิสัญญาไม่ว่าจะเป็นองค์กรฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ หรือตุลาการ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการกฎหมายภายในมารองรับ บังคับการให้เป็นไปตามผลของสนธิสัญญานั้นๆ ซึ่งมีวิธีการต่างๆ เช่นออกพระราชบัญญัติมารองรับสนธิสัญญา การออกกฎหมายให้เป็นไปตามสนธิสัญญา หรือ การนำข้อบทในสนธิสัญญา มาตราเป็นกฎหมาย เป็นต้น

สิ่งที่พึงจะต้องพิจารณาโดยรอบคอบคือการตั้งข้อสงวนในสนธิสัญญาในส่วนที่ภาคีไม่ประสงค์ที่จะต้องผูกพันตามสนธิสัญญา ข้อกำหนดในการที่สนธิสัญญาเริ่มมีผลบังคับ (Entry into force) การแก้ไขเพิ่มเติม (Amendment) การแก้ไขเปลี่ยนแปลง (Modification) การบอกเลิกสนธิสัญญา (Termination) หรือความล้มเหลวของสนธิสัญญา และข้อกำหนด Carve out, non-conforming, Exception ในการนี้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง General exception ที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะด้านต่างๆ ความมั่นคงแห่งชาติ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และ แกนแห่งอำนาจอธิปไตยของรัฐ (Core Sovereignty)

วิเคราะห์

วัตถุประสงค์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ ที่จะประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ว่ามีความตั้งใจเรียนและได้ศึกษาอ่านหนังสือมาครบถ้วนตามหลักเกณฑ์หรือไม่ (เป็นข้อสอบที่ให้ให้นักศึกษาออกข้อสอบเอง) ตอบตามที่ตนเองมีความรู้มากที่สุดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนได้ศึกษามาโดยละเอียด

ปรากฏว่านักศึกษาจำนวนมากไม่สามารถทำข้อสอบข้อนี้ได้ หรือทำผิด เช่นตอบกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล (หน่วยที่ 12-15) แทน ทั้งๆที่คำสั่งได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้ว หรือไม่ทำสอบเลย หรือนักศึกษาตอบโดยไม่มีหลักกฎหมาย ไม่มีหลักเกณฑ์ หรือ หุซฎีทางกฎหมาย จึงเป็นเรื่องที่สะท้อน ลักษณะการเรียนรู้ของนักศึกษาจำนวนหนึ่งเป็นอย่างดีว่าเหตุใดนักศึกษาเหล่านั้นจึงสอบไม่ผ่านวิชานี้ การไม่ได้ศึกษามาอย่างตั้งใจ จึงไม่สามารถตอบได้ ทั้งๆที่เป็นข้อสอบที่ง่ายมากที่สุดหากได้ศึกษามาอย่างดีแล้ว แต่กลับกลายเป็นข้อที่นักศึกษาทำไม่ได้มากที่สุด หรือไม่ได้ทำเลย

คำแนะนำ

นักศึกษาต้องมีความตั้งใจจริงในการเรียน และจงตระหนักว่า การเรียนนั้น คือการแสวงหาความรู้ หากมีความรู้แล้วการสอบไม่ใช่เรื่องลำบากยากเย็นอะไร การไม่มีความรู้ นั่นเอง คือ สาเหตุที่ทำให้สอบไม่ผ่าน ข้อสอบข้อนี้ เป็นเครื่องชี้ชัดว่านักศึกษา ได้ตั้งใจเรียนเพียงใด ยังมีโอกาสสอบซ่อมที่จะแก้ตัวใหม่ การเรียน

ต้องมีระเบียบวินัยในตนเอง ต้องมีความมุมานะ อุตสาหะ อดทน พากเพียร และ ที่สำคัญที่สุดคือต้องศึกษาจนเมือองค์ความรู้ที่ยั่งยืน อย่ามัวคัดเตาข้อสอบ เก็งข้อสอบ หวังพึ่งผู้อื่น ไม่ศึกษาด้วยตนเอง ผลจะปรากฏเช่นการสอบครั้งนี้ กล่าวคือไม่ว่าข้อสอบจะง่ายเพียงใดก็ไม่สามารถตอบได้เพราะไม่ได้ศึกษามาอย่างตั้งใจ จนมีความรู้เป็นของตนเอง

คำถาม

2. นักศึกษาจงวิเคราะห์จุดอ่อนของระบบการธำรงรักษาสันติภาพของโลก ภายใต้กรอบของสหประชาชาติ และ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้การวิเคราะห์ และการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหานั้นจะต้องมีหลักการทางกฎหมายระหว่างประเทศประกอบการคิดและวิเคราะห์

แนวตอบ

กลไกในการธำรงรักษาสันติภาพของโลก

สหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับจาก 192 ประเทศสมาชิกและมีบทบาทหน้าที่ในการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติตามที่ระบุในกฎบัตรสหประชาชาติ 2 ประการคือ

1. การแก้ไขข้อพิพาทด้วยสันติวิธี (หมวดที่ 6 ว่าด้วยการระงับกรณีพิพาทโดยสันติ : มาตรา 33-38)
2. การดำเนินการเพื่อระงับภัยคุกคามสันติภาพ การละเมิดสันติภาพหรือการใช้กำลังรุกราน (หมวดที่ 7 ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพ และการกระทำการรุกราน : มาตรา 39-51) ซึ่งถือเป็นมาตรการการใช้กำลังเพื่อให้เกิดสันติภาพ (peace enforcement)

การระงับข้อพิพาท และการนำประเด็นสู่ความสนใจของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสามารถกระทำ โดย

1. ผู้เป็นฝ่ายในกรณีพิพาทใด ๆ (มาตรา 33)
2. คณะมนตรีความมั่นคง (มาตรา 33, 34)
3. สมาชิกใดๆแห่งสหประชาชาติสามารถนำประเด็นสู่คณะมนตรีความมั่นคง (มาตรา 35 (1))
4. รัฐใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่ยอมรับยอมรับล่วงหน้าซึ่งข้อผูกพันเกี่ยวกับการระงับกรณีพิพาทโดยสันติ (มาตรา 35(2))
5. สมัชชาแห่งสหประชาชาติ (มาตรา 10, 11, 12)
6. เลขาธิการสหประชาชาติ (มาตรา 12 (2))

ดังข้อกำหนดในกฎบัตรสหประชาชาติดังนี้ ซึ่งกำหนดขั้นตอนและกระบวนการในการยุติข้อพิพาทหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศ

หมวดที่ 6 การระงับกรณีพิพาทโดยสันติ

มาตรา 33.

1. ผู้เป็นฝ่ายในการกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งหากดำเนินอยู่ต่อไปน่าจะเป็นอันตรายแก่การดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ก่อนอื่นจะต้องแสวงหาทางแก้ไขโดยการเจรจา การไต่สวน การไกล่เกลี่ย การประนีประนอม อนุญาโตตุลาการ การระงับโดยทางศาล การอาศัยทบวงการตัวแทนส่วนภูมิภาคหรือข้อตกลงส่วนภูมิภาค หรือสันติวิธี ยื่นใดที่คู่กรณีจะพึงเลือก

2. เมื่อเห็นว่าจำเป็น คณะมนตรีความมั่นคงจะต้องเรียกร้องให้คู่พิพาทระงับกรณีพิพาทของตนโดยวิธีเช่นว่า นั้น

มาตรา 34

คณะมนตรีความมั่นคงอาจสืบสวนกรณีพิพาทใด ๆ หรือสถานการณ์ใด ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ หรือก่อให้เกิดกรณีพิพาท เพื่อกำหนดลงไม่ว่าการดำเนินอยู่ต่อไปของการกรณีพิพาทหรือสถานการณ์นั้น ๆ น่าจะเป็นอันตรายแก่การดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศหรือไม่

มาตรา 35

1. สมาชิกใด ๆ ของสหประชาชาติอาจนำกรณีพิพาทใด ๆ หรือสถานการณ์ใด ๆ อันมีลักษณะตามที่กล่าวถึงใน มาตรา 34 มาเสนอคณะมนตรีความมั่นคงหรือสมัชชาได้

2. รัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของสหประชาชาติอาจนำกรณีพิพาทใด ๆ ซึ่งตนเป็นฝ่ายหนึ่งในการกรณีพิพาทมาเสนอ คณะมนตรีความมั่นคงหรือสมัชชาได้ ถ้ารัฐนั้นยอมรับล่วงหน้าซึ่งข้อผูกพันเกี่ยวกับการระงับกรณีพิพาทโดยสันติ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรฉบับปัจจุบัน เพื่อความมุ่งประสงค์ในการระงับกรณีพิพาท

3. การดำเนินการพิจารณาของสมัชชา ในเรื่องที่เสนอขึ้นมาตามข้อนี้ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของ มาตรา 11 และ 12

มาตรา 36

1. คณะมนตรีความมั่นคงอาจแนะนำวิธีดำเนินการ หรือวิธีการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสมได้ ไม่ว่าในระยะใด ๆ แห่งการพิพาทอันมีลักษณะตามที่กล่าวถึงใน มาตรา 33 หรือแห่งสถานการณ์อันมีลักษณะทำนองเดียวกันนั้น

2. คณะมนตรีความมั่นคงควรพิจารณาวิธีดำเนินการใด ๆ เพื่อระงับกรณีพิพาทซึ่งคู่พิพาทได้รับปฏิบัติแล้ว

3. ในการทำคำแนะนำตามข้อนี้ คณะมนตรีความมั่นคงควรพิจารณาด้วยว่า กรณีพิพาทในทางกฎหมายนั้นตามหลักทั่วไป ควรให้คู่พิพาทเสนอต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตามกฎหมายบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของศาลนั้น

มาตรา 37

1. หากผู้เป็นฝ่ายในการนิพิพิทาอันมีลักษณะตามที่กล่าวถึงใน มาตรา 33 ไม่สามารถระงับกรณีพิพาทได้โดยวิธีระงู ไว้ในข้อนั้นแล้ว ให้เสนอเรื่องนั้นต่อคณะกรรมการความมั่นคง
2. ถ้าคณะกรรมการความมั่นคงเห็นว่า โดยพฤติการณ์การดำเนินต่อไปแห่งกรณีพิพาทน่าจะเป็นอันตรายต่อการชำระไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศแล้ว ก็ให้วินิจฉัยว่าจะดำเนินการตาม มาตรา 36 หรือจะแนะนำข้อ กำหนดในการระงับกรณีพิพาทเช่นที่อาจพิจารณาเห็นเหมาะสม

มาตรา 38

โดยไม่กระทบกระเทือนต่อบทบัญญัติแห่ง มาตรา 33 ถึง 37 คณะมนตรีความมั่นคงอาจทำคำแนะนำ แก่คู่ พิพาทด้วยความมุ่งหมายในการระงับกรณีพิพาทโดยสันติ หากผู้เป็นฝ่ายทั้งปวง ในการนิพิพิทาใด ๆ ร้องขอเช่นนั้น

บทบาทของสมัชชา และ เลขาธิการสหประชาชาติในการธำรงรักษาสันติภาพ**มาตรา 10**

สมัชชาอาจอภิปรายปัญหาใด ๆ หรือเรื่องใด ๆ ภายในขอบข่ายแห่งกฎบัตรฉบับปัจจุบัน หรือที่เกี่ยวข้อง ไปถึงอำนาจและหน้าที่ขององค์การใด ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตรฉบับปัจจุบันได้ และอาจทำคำแนะนำ ไปยังสมาชิก ของสหประชาชาติ หรือคณะมนตรีความมั่นคง หรือทั้งสองแห่งในปัญหาหรือเรื่องราวใด ๆ เช่นว่า นั้นได้ เว้นแต่ที่ได้ บัญญัติไว้ใน มาตรา 12

มาตรา 11

1. สมัชชาอาจพิจารณาหลักการทั่วไปแห่งความร่วมมือ ในการชำระไว้ ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งหลักการควบคุมการลตอาวุธและการควบคุมกำลังอาวุธ และอาจทำคำแนะนำ เกี่ยวกับหลักการเช่นว่า ไปยังสมาชิก หรือคณะมนตรีความมั่นคง หรือทั้งสองแห่งก็ได้
2. สมัชชาอาจอภิปรายปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการชำระไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ อันได้ เสนอต่อสมัชชาโดยสมาชิกใด ๆ ของสหประชาชาติ หรือโดยคณะมนตรีความมั่นคง หรือโดยรัฐที่มีใช่ สมาชิกของสหประชาชาติตาม มาตรา 35 ววรรค 2 และ เว้นแต่ที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 12 อาจทำคำแนะนำ เกี่ยวกับปัญหาใด ๆ เช่นว่านั้นไปยัง รัฐหนึ่งหรือหลายรัฐที่เกี่ยวข้องหรือคณะรัฐมนตรีความมั่นคงหรือทั้งสองแห่ง ก็ได้ สมัชชาจะต้องส่งปัญหาใด ๆ เช่นว่า ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการไปยังคณะมนตรีความมั่นคงจะเป็นก่อนหรือ หลังการอภิปรายก็ได้
3. สมัชชาอาจแจ้งให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบสถานการณ์ซึ่งน่าจะเป็นอันตรายต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ
4. อำนาจของสมัชชาตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้จะต้องไม่จำกัดขอบข่ายทั่วไปของ มาตรา 10

มาตรา 12

1. ในขณะที่คณะกรรมการความมั่นคงกำลังปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ใด ๆ อันได้รับมอบหมายตามกฎหมายฉบับปัจจุบันอยู่นั้น สหประชาชาติจะต้องไม่ทำคำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับการกรณีพิพาทหรือสถานการณ์นั้น นอกจากคณะกรรมการความมั่นคงจะร้องขอ
2. โดยความยินยอมของคณะกรรมการความมั่นคง เลขานุการจะต้องแจ้งให้สมาชิกทราบทุกสมัยประชุมถึงเรื่องราวใด ๆ เกี่ยวกับการอ้างไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งคณะกรรมการความมั่นคงกำลังดำเนินการอยู่ และในทำนองเดียวกัน จะต้องแจ้งสมาชิกหรือสมาชิกของสหประชาชาติในกรณีที่มีสมาชิกได้อยู่ในสมัยประชุมให้ ทราบในทันทีที่คณะกรรมการความมั่นคงหยุดดำเนินการในเรื่องเช่นนั้น

หลักกฎหมายว่าด้วยกระบวนการและ กลไกในการรักษาสันติภาพของโลก

หมวดที่ 7 การดำเนินการเกี่ยวกับการคุกคามต่อสันติภาพการละเมิดสันติภาพ และการกระทำ การรุกราน

มาตรา 39

คณะกรรมการความมั่นคงจะต้องกำหนดว่า การคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพ หรือการกระทำ การรุกรานได้มีขึ้นหรือไม่ และจะต้องทำคำแนะนำหรือวินิจฉัยว่าจะใช้มาตรการใดตาม มาตรา 41 และ 42 เพื่ออ้างไว้หรือ สถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

มาตรา 40

เพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์ทวีความร้ายแรงยิ่งขึ้น คณะมนตรีความมั่นคงอาจเรียกร้องให้คู่กรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องอนุวัติตามมาตรการชั่วคราวเช่นที่เห็นจำเป็นหรือพึงปรารถนา ก่อนที่จะทำคำแนะนำ หรือวินิจฉัยมาตรการ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 39 มาตรการชั่วคราวเช่นว่านี้จะต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิ สิทธิเรียกร้องหรือฐานะของคู่ พิพาทที่เกี่ยวข้อง คณะมนตรีความมั่นคงจะต้องคำนึงถึงการไม่สามารถอนุวัติตามมาตรการชั่วคราว เช่นว่านั้นตามสมควร

มาตรา 41

คณะกรรมการความมั่นคงอาจวินิจฉัยว่า จะต้องใช้มาตรการใดอันไม่มีการใช้กำลังอาวุธ เพื่อให้เกิดผลตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการความมั่นคงและอาจเรียกร้องให้สมาชิกของสหประชาชาติใช้มาตรการเช่นว่านั้น มาตรการ เหล่านี้อาจรวมถึงการหยุดชะงักซึ่งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข ทางวิทยุ และวิธีทางคมนาคมอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน และการตัดความสัมพันธ์ทาง การทูตด้วย

มาตรา 42

หากคณะกรรมการความมั่นคงพิจารณาว่า มาตรการตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 41 จะไม่เพียงพอ หรือได้พิสูจน์แล้วว่าไม่เพียงพอ คณะมนตรีอาจดำเนินการใช้กำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดิน เช่นที่อาจ

เห็นจำเป็นเพื่อ ชำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การดำเนินการ เช่นนี้อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปิดล้อมและการปฏิบัติการอย่างอื่นโดยกำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดิน ของบรรดา สมาชิกของสหประชาชาติ

มาตรา 43

1. เพื่อได้มีส่วนเกี่ยวเนื่องในการชำระไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ สมาชิกทั้งปวง ของสหประชาชาติ รับผิดชอบจัดสรรกำลังอาวุธความช่วยเหลือ และความสะดวก รวมทั้งสิทธิในการผ่านดินแดน ตามที่จำเป็นเพื่อ ความมุ่งประสงค์ในการชำระไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ให้แก่คณะมนตรี ความมั่นคง เมื่อคณะมนตรีฯ เรียกร้องและเป็นไปตามความตกลงพิเศษฉบับเดียวหรือหลายฉบับ

2. ความตกลงฉบับเดียวหรือหลายฉบับเช่นว่านั้น จะต้องกำหนดจำนวนและประเภทของกำลัง ขึ้นแห่งการเตรียมพร้อมและที่ตั้งโดยทั่วไปของกำลังและลักษณะของความสะดวกและความช่วยเหลือที่จะจัดทำให้

3. ให้ดำเนินการเจรจาทำความตกลงฉบับเดียวหรือหลายฉบับนั้นโดยความริเริ่มของคณะมนตรี ความมั่นคง โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ความตกลงเหล่านี้จะต้องทำกันระหว่างคณะมนตรีความมั่นคงและสมาชิก หรือระหว่างคณะมนตรีความมั่นคงและกลุ่มสมาชิก และจะต้องได้รับการสัตยาบันโดยรัฐที่ลงนามตามการบวนการ ทางรัฐธรรมนูญของรัฐเหล่านั้น

มาตรา 44

เมื่อคณะมนตรีความมั่นคงได้วินิจฉัยที่จะใช้กำลังแล้ว ก่อนที่จะเรียกร้องให้สมาชิกซึ่งมิได้มีผู้แทน อยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงจัดส่งกำลังทหารเพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ได้ยอมรับตาม มาตรา 43 คณะมนตรี ความมั่นคง จะต้องเชิญสมาชิกนั้นให้เข้าร่วมในการวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคงเกี่ยวกับการใช้กองกำลังทหาร ของสมาชิก นั้น หากสมาชิกนั้นปรารถนาเช่นนั้น

มาตรา 45

เพื่อให้สหประชาชาติสามารถดำเนินมาตรการทางทหารได้โดยด่วนสมาชิกจะต้องจัดสรรกองกำลัง ทางอากาศแห่งชาติไว้ให้พร้อมโดยทันทีเพื่อการดำเนินการบังคับระหว่างประเทศร่วมกัน กำลังและขึ้นแห่ง การเตรียมพร้อมของกองกำลังเหล่านี้ และแผนการสำหรับการดำเนินการร่วมจะต้องกำหนดโดยคณะมนตรี ความมั่นคง ด้วยความช่วยเหลือของคณะกรรมการเสนาธิการทหารทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่วางไว้ในความตกลงพิเศษ ฉบับเดียวหรือหลายฉบับ ที่อ้างถึงใน มาตรา 43

มาตรา 46

แผนการสำหรับการใช้สำหรับทหารจะต้องจัดทำโดยคณะมนตรีความมั่นคง ด้วยความช่วยเหลือของ คณะกรรมการเสนาธิการทหาร

มาตรา 47

1. ให้จัดสถาปนาคณะกรรมการเสนาธิการทหารขึ้นคณะหนึ่งเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ คณะมนตรีความ มั่นคงในปัญหาทั้งปวงที่เกี่ยวกับความต้องการทางทหารของคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อ การชำระ

ไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การใช้และการบังคับบัญชากำลังทหารที่มอบให้อยู่ในอำนาจจัดการของคณะมนตรีฯ การควบคุมกำลังอาวุธ และการลดอาวุธอันจะพึงเป็นไปได้

2. คณะกรรมการสิทธิการทหารจะต้องประกอบด้วยสมาชิกการทหารของสมาชิกประจำของคณะมนตรีความมั่นคงหรือผู้แทนของบุคคลเหล่านี้คณะกรรมการฯ จะต้องเชิญสมาชิกของสหประชาชาติที่มีได้มีผู้แทนประจำอยู่ใน คณะกรรมการฯ เข้าร่วมงานกับคณะกรรมการฯ ด้วย เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ให้ มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องให้สมาชิกเหล่านั้นเข้าร่วมในการทำงานของคณะกรรมการฯ

3. คณะกรรมการสิทธิการทหารจะต้องรับผิดชอบภายใต้คณะมนตรีความมั่นคงสำหรับการบัญชาการทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการใช้กำลังทหารใด ๆ ซึ่งได้มอบไว้ให้อยู่ในอำนาจจัดการของคณะมนตรีความมั่นคงเรื่องเกี่ยวกับ การบังคับบัญชาทหารเหล่านั้นจะได้ดำเนินการในภายหลัง

4. คณะกรรมการสิทธิการทหารอาจสถาปนาคณะอนุกรรมการส่วนภูมิภาคขึ้นได้ ทั้งนี้โดยได้รับมอบอำนาจ จากคณะมนตรีความมั่นคงและหลังจากได้ปรึกษาหารือกับทบวงการตัวแทนส่วนภูมิภาคที่เหมาะสมแล้ว

มาตรา 48

1. การดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและ ความมั่นคงระหว่างประเทศจะต้องกระทำโดยสมาชิกของสหประชาชาติทั้งปวงหรือแต่บางประเทศตามแต่คณะมนตรี ความมั่นคงจะพึงกำหนด

2. คำวินิจฉัยเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามโดยสมาชิกของสหประชาชาติโดยตรง และโดยผ่านการดำเนินการของสมาชิกเหล่านั้นในทบวงการตัวแทนระหว่างประเทศที่เหมาะสมซึ่งตนเป็นสมาชิกอยู่

มาตรา 49

สมาชิกของสหประชาชาติจะต้องร่วมกันอำนวยความสะดวกซึ่งกันและกันในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการที่คณะมนตรีความมั่นคงได้วินิจฉัยไว้แล้ว

มาตรา 50

หากคณะมนตรีความมั่นคงได้ดำเนินมาตรการป้องกันหรือบังคับต่อรัฐใดรัฐอื่นไม่ว่าจะเป็นสมาชิกของสหประชาชาติหรือไม่ ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหาพิเศษทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นย่อมมี สิทธิที่จะปรึกษาหารือกับคณะมนตรีความมั่นคงเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหานั้น

มาตรา 51

ไม่มีข้อความใดในกฎบัตรฉบับปัจจุบันจะรอนสิทธิประจำตัวในการป้องกันตนเองโดยลำพังหรือโดยร่วมกัน หากการโจมตีด้วยกำลังอาวุธบังเกิดแก่สมาชิกของสหประชาชาติ จนกว่าคณะมนตรีความมั่นคงจะได้ดำเนิน มาตรการที่จำเป็นเพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศมาตรการที่สมาชิกได้ดำเนินไปในการใช้สิทธิป้องกันตนเองนี้จะต้องรายงานให้คณะมนตรีความมั่นคงทราบโดยทันที และจะต้องไม่กระทบกระเทือนอำนาจ และความรับผิดชอบของคณะมนตรีความมั่นคงตามกฎหมายฉบับปัจจุบันแต่ประการใด ในอันที่จะดำเนินการเช่นที่เห็น จำเป็นไม่ว่าในเวลาใด เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับคืนมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ

จะเห็นได้ว่า คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเป็นกลไกของสหประชาชาติที่มีอำนาจในการวินิจฉัยและดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อระงับ/ยุติความขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้น แม้ว่าประเทศสมาชิกสหประชาชาติจะสามารถยับยั้งปัญหาความขัดแย้งขึ้นสู่การพิจารณาของสมัชชาสหประชาชาติได้ แต่อำนาจของสมัชชา จำกัดอยู่เพียงการให้คำแนะนำ โดยไม่มีอำนาจเหมือนคณะมนตรีความมั่นคงฯ

บทบาท/ภาระหน้าที่ของปฏิบัติการรักษาสันติภาพจำกัดเพียง เฉพาะทางด้านทหารในการตรวจสอบ/ตรวจตรา/และรายงานการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงหรือข้อตกลงสันติภาพชั่วคราว การจัดตั้งและกำหนดอาณาเขตจึงเป็นปฏิบัติการตามหมวดที่ 6 ของกฎบัตรฯ (Peaceful Settlement) โดยยึดหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ

1. การได้รับความยินยอม (Consent) จากประเทศที่เกี่ยวข้อง การไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (Impartiality)
2. การไม่ใช้กำลัง ยกเว้นกรณีป้องกันตัว (Non-use of Force)

สรุปกลไกในการธำรงรักษาสันติภาพของโลก

หมวดที่ 6 และ 7 ของกฎบัตรสหประชาชาติ ในเรื่องการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศได้กำหนด กลไกในการรักษาสันติภาพของโลกโดยให้อำนาจรัฐสมาชิก (มาตรา 35 (1), รัฐอื่นที่ไม่ใช่สมาชิกแต่ยอมรับล่วงหน้าซึ่งข้อผูกพันแห่งการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีตามที่บัญญัติไว้ในกฎบัตร (มาตรา 35 (2), สมัชชา (ตามมาตรา 10 และมาตรา 11) หรือ เลขาธิการ (มาตรา 12 (2) ในการยับยั้งประเด็นปัญหา สู่ความสนใจของคณะมนตรีความมั่นคงเพื่อการตรวจสอบ ทั้งนี้ มาตรา 39 คณะมนตรีความมั่นคงจะกำหนดว่า การคุกคามต่อสันติภาพ การละเมิดสันติภาพหรือการกระทำการรุกรานได้มีขึ้น หรือไม่ และจะทำคำแนะนำหรือวินิจฉัยว่าจะใช้มาตรการอันใดตามมาตรา 41 และ 42 เพื่อธำรงไว้หรือสถาปนากลับ คินมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ และเพื่อป้องกันมิให้สถานการณ์ทวีความร้ายแรงยิ่งขึ้น คณะมนตรีความมั่นคงอาจเรียกร้องให้คู่กรณีพิพาท ที่เกี่ยวข้องอนุวัติตามมาตรการชั่วคราวเช่นที่เห็นจำเป็นหรือพึงปรารถนา ก่อนที่จะทำคำแนะนำ หรือวินิจฉัยมาตรการ ตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 39 นอกจากนั้น ตามมาตรา 41 คณะมนตรีความมั่นคงและอาจเรียกร้องให้สมาชิกของสหประชาชาติใช้มาตรการ บอยคอต แสงขึ้น ในวิธีการต่างๆ รวมถึงการหยุดชะงักซึ่งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และการคมนาคมทางรถไฟ ทางทะเล ทางอากาศ ทางไปรษณีย์ ทางโทรเลข ทางวิทยุ และวิธีทางคมนาคมอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วน และการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตด้วย เพื่อให้ประเทศที่ถูกคุกคามต่อสันติภาพของโลกยุติการกระทำดังกล่าว

หากการใช้มาตรการบอยคอต แสงขึ้นไม่ประสบความสำเร็จ คณะมนตรีฯอาจดำเนินการใช้กำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดิน เช่นที่อาจเห็นจำเป็นเพื่อ ธำรงไว้หรือสถาปนากลับคินมาซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ การดำเนินการเช่นนี้อาจรวมถึงการแสดงแสนยานุภาพ การปิดล้อมและการปฏิบัติการอย่างอื่นโดยกำลังทางอากาศ ทางทะเล หรือทางพื้นดิน ของบรรดา สมาชิกของสหประชาชาติตามมาตรา 42 จนถึงขั้นการจัดตั้งกองกำลังสหประชาชาติ ตามข้อ 43-48 โดยลำดับ

จุดอ่อนของกลไกการธำรงรักษาสันติภาพ

1. สมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง 5 ประเทศ อันประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย จีน เป็นประเทศมหาอำนาจ ย่อมมีอิทธิพลต่อประเด็นปัญหา ที่ประเทศเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้อง และทำให้ขาดความเป็นกลาง อีกทั้งการมีสิทธิวีโต้ ของสมาชิกถาวรทำให้ไม่สามารถออกข้อมติได้หากประเทศสมาชิกถาวรไม่มีความเป็นเอกภาพ ในทางตรงข้ามการใช้อำนาจวีโต้ของสมาชิกถาวร ทำให้แสดงให้เห็นถึงการรวมกลุ่มอิทธิพลต่อประเด็นปัญหาข้อพิพาท หรือ ความขัดแย้งได้ เช่น กรณีพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา ฝรั่งเศส เป็นประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อเท็จจริงต่อการแก้ไขพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในประเด็นเขตแดนของรัฐทั้งสอง หากมีการนำข้อพิพาทสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ฝรั่งเศสย่อมมีอิทธิพล หรือ การก่อเกิดการออกมติเป็นเอกภาพร่วมกับฝรั่งเศสได้โดยง่าย ซึ่งฝรั่งเศสย่อมเห็นด้วยกับกัมพูชามากกว่าไทยเพราะหากกัมพูชาแพ้เท่ากับฝรั่งเศสแพ้ ฝรั่งเศสย่อมไม่มีวันเข้าข้างฝ่ายไทย และ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออกมติของสมาชิกถาวรอีก 4 ประเทศได้ แต่หากสมาชิกอีก 4 ประเทศไม่เข้าข้างฝรั่งเศส ฝรั่งเศสย่อมใช้สิทธิวีโต้ มติย่อมตกไป จะเห็นได้ว่า หากสมาชิกถาวรใดเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือ เกี่ยวข้องกับกรณีพิพาท ความเป็นกลางย่อมไม่อาจจะเกิดขึ้นได้ดังกรณีไทย และกัมพูชา เป็นต้น จัดเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุด ในอดีต รัสเซียก็เคย Walk Out ในกรณีของเกาหลีเหนือมาแล้ว ทำให้ไม่สามารถออกมติเอกฉันท์ได้ เพราะรัสเซียสนับสนุนเกาหลีเหนือ จนในท้ายที่สุดสมัชชาต้องหาทางออกโดยมีมติขีชีล้นออกมาแก้ไข เป็นการขยายอำนาจของสมัชชาในการออกมติแทนคณะมนตรีความมั่นคงในขณะนั้นเพื่อส่งกองกำลังไปช่วยรบในสงครามเกาหลี เป็นต้น

2. ลักษณะการใช้กำลังเพื่อให้เกิดสันติภาพภายใต้หมวดที่ 7 ของกฎบัตร เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นข้อจำกัดของปฏิบัติการรักษาสันติภาพที่มาจากสาเหตุสำคัญ คือ (1) สหประชาชาติต้องพึ่งการสนับสนุนทั้งหมดจากประเทศสมาชิก ทำให้การจัดกำลังแต่ละครั้งต้องใช้เวลารวบรวมกำลังพล และอาจจะได้ไม่ครบตามที่วางแผนไว้ (2) องค์ประกอบด้านบุคลากร ยุทโธปกรณ์ และการบังคับบัญชาไม่เอื้ออำนวยให้จัดหน่วยรบที่มีประสิทธิภาพได้ (3) การปฏิบัติการ ลักษณะการใช้กำลังเพื่อให้เกิดสันติภาพมีระดับความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน ซึ่งการสูญเสียเพียงเล็กน้อยที่เกิดกับกองกำลังอาจก่อให้เกิดกระแสสังคมภายในประเทศกดดันให้รัฐบาลต้องถอนการสนับสนุน ซึ่งอาจทำให้ปฏิบัติการรักษาสันติภาพนั้นๆ ต้องล้มเลิกไปในที่สุด

แนวทางการแก้ไขปัญหาของสหประชาชาติ

1. ไม่ควรให้สิทธิสมาชิกถาวรของคณะมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีพิพาท ใช้สิทธิออกเสียงหรือวีโต้ หรือ หากเป็นไปได้ ควรใช้มติเสียงข้างมากแทน หรือ ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นสมาชิกหมุนเวียนทั้ง 15 ประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องมีสมาชิกถาวร 5 ประเทศอีกต่อไป

2. สหประชาชาติจึงให้ความสำคัญกับการปฏิรูปปฏิบัติการรักษาสันติภาพ เช่น การปรับโครงสร้างสำนักเลขาธิการสหประชาชาติ โดยให้ Department of Peacekeeping Operations (DPKO) รับผิดชอบงานด้านการวางแผนและจัดการกองกำลังและปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และจัดตั้ง Department of Field Support (DFS) เพื่อรับผิดชอบด้าน Logistics แก่กองกำลังและปฏิบัติการรักษาสันติภาพ รวมถึงบุคลากร งบประมาณ และการสื่อสาร และโครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ของปฏิบัติการรักษาสันติภาพ (New Horizon Project)

เพื่อวิเคราะห์เชิงรุกเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายของปฏิบัติการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติอันเป็นผลจากสภาพปัญหาความขัดแย้งที่เปลี่ยนแปลงไป

วิเคราะห์

วัตถุประสงค์

ข้อสอบข้อนี้ต้องการประเมิน ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกในการธำรงรักษาสันติภาพของโลก (Peace Keeping Mechanism) โดยสหประชาชาติ และ บทบาทของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ปรากฏว่านักศึกษาจำนวนมากตอบไม่ได้เลย แต่จะตอบไปตามความคิดเห็นของตนเองส่วนตัว โปรดระลึกไว้เสมอว่าการศึกษากฎหมายต้องตอบหลักกฎหมาย ไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิด **โดยไม่มีหลักกฎหมายรองรับ** นักศึกษาไม่ได้ตอบกลไกในการธำรงรักษาสันติภาพ ตามกฎบัตรสหประชาชาติ ไม่ได้ตอบอำนาจหน้าที่ขององค์กรต่างๆ ตามกลไกที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ ไม่ได้ตอบว่าฝ่ายใดบ้างมีสิทธินำเสนอประเด็นสู่การพิจารณาของคณะมนตรีความมั่นคง นักศึกษาไม่ได้ตอบกระบวนการธำรงรักษาสันติภาพว่าต้องดำเนินการอย่างไร แล้วจึงพิจารณาว่ากลไกเหล่านั้นมีข้อบกพร่องอย่างไร มีจุดอ่อนอย่างไร จึงจะสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมาย ทั้งๆที่ข้อสอบข้อนี้อยู่ในหนังสือ ทั้งหมด นำเสียดายที่นักศึกษาไม่ได้อ่านให้ลึกซึ้งและเข้าใจ

คำแนะนำ

นักศึกษาต้องศึกษาให้เข้าใจเนื้อหาสาระ และหลักกฎหมายอย่างแท้จริง ไม่ว่าอ่านตำรากฎหมายใดๆ ต้องอ่านให้เข้าใจจิตวิญญาณของกฎหมาย พบหลักกฎหมาย เข้าใจในแก่นแท้ของสิ่งที่ศึกษา ต้องจับใจความให้ได้ว่าตำราได้สื่ออะไรให้นักศึกษารู้ ให้ความรู้เรื่องอะไร อย่าอ่านตำราสักแต่ว่าอ่านไปโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย อ่านแล้วสามารถค้นหาคำตอบให้ได้ว่าคืออะไร หน่วยการสอนแต่ละหน่วยจะเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าต้องการให้นักศึกษารู้เรื่องอะไร ในแผนหน่วย แผนตอน และกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว อ่านแล้วต้องประเมินตนเองได้ว่ารู้และเข้าใจในสิ่งที่อ่านหรือไม่ อย่างไร

คำถาม

ข้อ 3. นักศึกษาจงวิเคราะห์ปัญหาในการบังคับใช้มาตรา 23 ของพระราชบัญญัติสัญญา พ.ศ. 2508 แก้ไข พ.ศ. 2535 และแก้ไข พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้ว่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติ และการบังคับใช้อย่างไร และจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายังไร **จงวิเคราะห์ในประเด็นหลักกฎหมาย** ประกอบในการคิดและวิเคราะห์

มาตรา 23 บรรดาบุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ข้อ 1 และผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ข้อ 2 รวมถึงบุตรของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและ

ไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 ซึ่งเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ถ้าบุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกันโดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และเป็นผู้มีความประพฤติดี หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทยให้ได้สัญชาติไทยตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่ผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคำสั่งอันมีผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ผู้มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งยื่นคำขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎรต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาในปัจจุบัน

แนวตอบ

นักศึกษาสามารถตอบแนวคิดได้กว้างขวางและลึกซึ้ง โดยต้องมีหลักเกณฑ์ของกฎหมายมาตอบสนับสนุน ไม่ใช้การนึกคิดไปตามความเห็นส่วนตัวโดยไม่มีหลักกฎหมายรองรับ

มาตรา 23 พระราชบัญญัติสัญชาติ ที่แก้ไขใหม่ ปี พ.ศ. 2551 ได้กำหนดบุคคลที่ได้รับสิทธิในการได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายใหม่ เนื่องจากบุคคลเหล่านี้ไม่ได้สัญชาติไทยตามกฎหมายเดิมดังนี้

1. บุคคลที่เคยมีสัญชาติไทยเพราะเกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ถูกถอนสัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ข้อ 1 ซึ่งหมายถึงบุคคลที่เคยได้สัญชาติไทยตามหลักดินแดน แต่ต่อมาในปี 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ออกมาถอนสัญชาติไทยของบุคคลเหล่านั้น เนื่องจากเป็นบุคคลที่เข้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะถูกถอนสัญชาติกล่าวคือ ข้อ 1 ให้ถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะที่เกิดบิดาหรือมารดานั้นเป็น (1) ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย (2) ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ (3) ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสั่งเฉพาะรายเป็นประการอื่น ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ออกมาเพื่อป้องกันความมั่นคงของประเทศไทยเนื่องจากมีผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีการสู้รบกันหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยจำนวนมาก เช่น กลุ่มคนอพยพจากประเทศเวียดนามในขณะนั้น หรือ ที่เรียกว่า ญวนอพยพ

2. ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทยตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 337 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 ข้อ 2 หมายถึงบุคคลที่แม่เกิดมาในราชอาณาจักรไทยแต่ไม่ได้สัญชาติไทย เพราะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามประกาศคณะปฏิวัติที่ไม่ให้สัญชาติไทย ในขณะที่ประกาศคณะปฏิวัติฉบับนี้ออกใช้บังคับแล้ว ตามคุณสมบัติในข้อ 1 ข้างต้น

3. บุตรของบุคคลดังกล่าว ที่เกิดในราชอาณาจักรไทยก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและหมายถึงบุคคลที่เป็นบุตรของบุคคลตามข้อ 1 และ 2 ข้างต้น แม้เกิดในราชอาณาจักรไทยแต่เข้าช้อยกเว้นไม่ได้สัญชาติไทย

4. บุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508

5. แต่กฎหมายใหม่ฉบับนี้ยกเว้นบุคคลผู้ซึ่งรัฐมนตรีมีคำสั่งอันมิผลให้เป็นผู้มีสัญชาติไทยแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หมายความว่าบุคคลที่ไม่ได้สัญชาติไทย เช่นบุคคลตามมาตรา 7 ทวิ ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย แต่รัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ได้รับสัญชาติไทยไปแล้ว ดังนั้นแม้เป็นบุคคลที่เข้าอยู่ในมาตรา 7 ทวิ แต่เมื่อได้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะรายไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องให้ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายใหม่ฉบับนี้อีก

กฎหมายใหม่ฉบับนี้ให้บุคคลเหล่านี้ตาม ข้อ 1-4 **ได้รับสัญชาติไทย** กล่าวคือได้รับสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายหากเข้าคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด แต่ต้องยื่นคำขอลงรายการสัญชาติในเอกสารการทะเบียนราษฎร ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรแห่งท้องที่ที่ผู้นั้นมีภูมิลำเนาในปัจจุบัน จึงไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือบุคคลผู้มีอำนาจอื่นใดในการพิจารณาให้ได้รับสัญชาติไทย เช่นมาตราอื่นๆของพระราชบัญญัติสัญชาติ

ดังนั้นจึงขาดการกลั่นกรองโดย**ผู้มีอำนาจรับผิดชอบ**ตามที่กฎหมายกำหนด ปัญหานี้เกี่ยวเนื่องต่อไปถึงเรื่องคุณสมบัติ กล่าวคือ

คุณสมบัติที่บุคคลทั้ง 4 ข้อข้างต้นจะได้รับสัญชาติไทยโดยผลของกฎหมายคือ

1. บุคคลผู้นั้นอาศัยอยู่จริงในราชอาณาจักรไทยติดต่อกัน
2. โดยมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
3. และเป็นผู้มีความประพฤติดี หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมหรือประเทศไทย

เมื่อไม่มีบุคคลที่มีอำนาจรับผิดชอบกลั่นกรอง แต่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับสัญชาติไทย แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ว่าใครเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติทั้ง 3 ประการนั้น จึงเกิดปัญหาว่า ใครจะเป็นผู้พิจารณาว่าบุคคลนั้นอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยจริงติดต่อกัน และอยู่ติดต่อกันนานเพียงใด และจะได้**หลักฐานทางทะเบียนราษฎร**มาอย่างไร และ **มาตรฐานการมีความประพฤติดีแค่ไหน** หรือ **การทำคุณประโยชน์ต้องทำขนาดไหน** ในเมื่อกฎหมายไม่ได้กำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาการกลั่นกรอง แม้จะกำหนดให้มีการยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น แต่กฎหมายก็ไม่ได้กำหนด อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องนี้แต่ประการใด และไม่ได้กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

ดังนั้นโอกาสในการที่บุคคลต่างตัวจะเข้ามาสวมสิทธิ ว่าอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยจริง ติดต่อกัน และมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร และอาจจะเป็นช่องทางให้มีการทำหลักฐานเหล่านี้ได้ หรือ อย่างไรเรียกว่ามีความประพฤติดี หรือ ทำคุณประโยชน์ดีต่อบ้านเมือง ใครเป็นผู้พิจารณา เนื่องจากกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้เช่นกัน

เมื่อมีปัญหาช่องว่างของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทางปฏิบัติ ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงอาจก่อให้เกิดช่องทางที่คนต่างตัวเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและได้รับสัญชาติไทยโดยไม่ชอบมากขึ้น หรือ แม้เป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากบุคคลเหล่านี้ก็ยอมได้รับสัญชาติไทยไปด้วย เมื่อบิดา มารดาได้รับสัญชาติไทยไปแล้ว ทั้งๆที่บุคคลที่เกิดมานั้นจะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 7 ทวิ ซึ่งจะไม่ได้รับสัญชาติไทย และบุคคลเหล่านี้ไม่ได้เข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา 23 ข้างต้น

จึงเห็นสมควรที่จะต้องพิจารณาแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายในมาตรานี้ให้รัดกุมและมีการกำหนดหลักเกณฑ์ และบุคคลผู้มีอำนาจ หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการพิจารณาการกลั่นกรอง บังคับใช้กฎหมายตามวัตถุประสงค์

ในการช่วยเหลือคนที่เกิดในแผ่นดินไทยแต่ไร้สัญชาติ หรือ ไม่ได้สัญชาติจนเกิดเป็นปัญหาตามตะเข็บชายแดนมากมาย แต่ต้องคำนึงถึงผลการบังคับใช้กฎหมายไม่ให้เป็นช่องทางให้มีการทุจริต เพราะกฎหมายมีช่องว่างและปัญหาในการบังคับใช้อันจะทำให้ผิดวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายฉบับนี้

วิเคราะห์

วัตถุประสงค์

ข้อสอบข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการประเมินว่านักศึกษาสามารถอ่านตัวบท และ วิเคราะห์ ตัวบทกฎหมายได้หรือไม่ ข้อสอบได้ยกตัวบทมาให้อ่าน วิเคราะห์ ครบถ้วน หากนักศึกษาจะต้องใช้กฎหมายเหล่านี้ นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ อ่านตัวบทได้ หรือไม่ สามารถวิเคราะห์ จุดอ่อน ข้อเสียของกฎหมายได้หรือไม่ จะสามารถแก้ไขปัญหที่เกิดจาก สาระตะของกฎหมายได้หรือไม่

ปรากฏว่านักศึกษาจำนวนมากไม่สามารถเข้าใจตัวบทกฎหมาย ตีความกฎหมายไม่ได้ วิเคราะห์กฎหมายไม่ได้ และไม่สามารถตอบได้ว่ามีข้อบกพร่อง และจุดอ่อนของกฎหมายอย่างไร หากนำไปใช้ในทางปฏิบัติแล้วจะเกิดปัญหาได้ขึ้น

คำแนะนำ

นักศึกษาต้องฝึกการอ่าน และวิเคราะห์กฎหมาย การเรียนกฎหมายไม่ใช่การท่องจำตัวบท แต่ต้องเข้าใจหลักกฎหมาย วิเคราะห์ได้ ใช้เป็น สามารถมองเห็นปัญหาในทางปฏิบัติจากการใช้กฎหมายได้ เพื่อการแก้ไขกฎหมายต่อไป นักกฎหมายได้ชื่อว่าเป็นนักสร้างที่สร้างสรรค์ เป็นวิศวกรสังคม ทำสังคมให้น่าอยู่ กฎหมายเป็นสิ่งที่มีชีวิต มีจิตวิญญาณ สามารถอ่านveyความยุติธรรมแก่สมาชิกในสังคมได้ กฎหมายจึงต้องถูกสร้างมาอย่างเหมาะสม และ มีความเที่ยงธรรมในตัวเอง และต้องอาศัยนักกฎหมายที่มีความคิด วิเคราะห์ อย่างลึกซึ้งสามารถนำกฎหมายไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์



กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน

รองศาสตราจารย์ วิกรณ์ รักษ์ปวงชน

คำถาม

ดินเข้าไปทำสวนในที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แตนเจ้าของที่ดินเมื่อเปล่าข้างเคียงได้ทำทางเดินผ่านสวนของดินดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อดินทราบเรื่องจึงห้ามมิให้แดนผ่านที่ดินของตนอีกต่อไป แตนต่อสู้ว่าที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินผู้ใดก็มีสิทธิใช้ประโยชน์ได้ เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่าดินจะมีข้อต่อสู้อย่างไรหรือไม่

แนวตอบ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1374 วรรคหนึ่ง ถ้าผู้ครอบครองถูกรบกวนในการครอบครองทรัพย์สิน เพราะมีผู้สอดเข้าเกี่ยวข้องโดยมิชอบด้วยกฎหมายไว้ ทว่าผู้ครอบครองมีสิทธิจะให้ปลดเปลื้องการรบกวนนั้นได้ ถ้าเป็นที่น่าวิตกว่าจะยังมีการรบกวนอีก ผู้ครอบครองจะขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้

ตามปัญหา การที่ดินเข้าไปทำสวนในที่ดินแปลงหนึ่งซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และแดนเจ้าของที่ดินเมื่อเปล่าข้างเคียงได้ทำทางเดินผ่านสวนของดินดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น แม้การเข้าไยถือครอบครองที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็มีผลเพียงทำให้ดินผู้ครอบครองไม่อาจยกสิทธิใด ๆ ขึ้นโต้แย้งรัฐได้เท่านั้น แต่ในระหว่างราชฎด้วยกัน ดินผู้ครอบครองทำประโยชน์อยู่ก่อนยอมยกการยึดถือครอบครองนั้นขึ้นยื่นต่อแดนผู้เข้ามารบกวนการครอบครองได้ (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3973/2548)

ฉะนั้น ดินจึงยกข้อต่อสู้ดังกล่าวเพื่อให้ปลดเปลื้องการรบกวนการครอบครองนั้น

วิเคราะห์

ในเรื่องการครอบครองนั้น สิทธิครอบครองได้มาตามพฤติการณ์ข้อเท็จจริง แม้การได้มาจะเป็นการที่มีชัยด้วยกฎหมาย แต่ผู้ได้การครอบครองมาก็ย่อมได้สิทธิครอบครอง เป็นต้นว่าขโมยลักทรัพย์ของผู้อื่นมา ขโมยก็ย่อมได้สิทธิครอบครอง ใครจะมาแย่งเอาไปอีกต่อหนึ่ง ขโมยก็มีสิทธิต่อสู้ขัดขวางได้ ตามคำกล่าวที่ว่า "ขโมยย่อมมีสิทธิดีกว่าขโมย" กรณีเพียงแต่จะยกขึ้นต่อสู้กับเจ้าของกรรมสิทธิไม่ได้เท่านั้น กรณีตามคำถามนี้ก็เช่นเดียวกัน การเข้าไปทำสวนในที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน แม้จะเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ได้สิทธิครอบครอง เมื่อมีผู้อื่นเข้ามาทำทางผ่านอันเป็นการรบกวนการครอบครอง ผู้ครอบครองก็มีสิทธิจะเรียกให้ปลดเปลื้องการรบกวนนั้นได้ เพียงแต่จะขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินไม่ได้เท่านั้น

คำถาม

นิตกับหน้อยเป็นเจ้าของเรือนไม้สักหลังหนึ่งร่วมกัน ต่อมาเรือนไม้สักหลังดังกล่าวชำรุดทรุดโทรมมากจนยากที่จะซ่อมแซมได้ นิตจึงได้รื้อเรือนไม้สักหลังดังกล่าว แล้วปลูกสร้างเรือนหลังใหม่โดยใช้ไม้สักจากเรือนหลังเดิมเป็นส่วนประกอบทั้งหมด ซึ่งทำให้เรือนหลังใหม่เล็กลงกว่าเดิมเล็กน้อย หลังจากสร้างเรือนหลังใหม่เสร็จแล้วหน้อยจึงทราบเรื่อง และเรียกให้นิตทำให้บ้านกลับไปเป็นตามเดิม โดยอ้างว่านิตทำไปโดยพลการไม่ได้รับความยินยอมจากตนซึ่งเป็นเจ้าของรวม จึงเป็นการกระทำที่มีข้อบกพร่อง เช่นนี้ให้ท่านวินิจฉัยว่า ข้ออ้างของหน้อยรับฟังได้หรือไม่

แนวตอบ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1358 วรรคสอง “ในเรื่องจัดการตามธรรมดา ท่านว่า ฟังตกลงโดยคณะข้างมากแห่งเจ้าของรวมแต่เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ อาจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางจัดการตามธรรมดาได้ เว้นแต่ฝ่ายข้างมากได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น แต่เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ อาจทำการเพื่อรักษาทรัพย์สินได้เสมอ”

ตามปัญหา เรือนไม้สักอันเป็นการรวมสิทธิ์รวมของนิตกับหน้อยนั้น ชำรุดทรุดโทรมมากจนยากที่จะซ่อมแซมได้ การที่นิตเจ้าของรวมคนหนึ่งได้รื้อเรือนไม้สักหลังดังกล่าวแล้วปลูกสร้างเรือนหลังใหม่โดยใช้ไม้สักจากเรือนหลังเดิมเป็นส่วนประกอบทั้งหมดนั้น เป็นการจัดการเพื่อรักษาทรัพย์สิน เจ้าของรวมคนหนึ่งๆ มีสิทธิทำได้โดยลำพัง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1358 วรรคสอง ดังกล่าว (เทียบคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 281/2520) ไม่เป็นละเมิดต่อเจ้าของรวมคนอื่น

ฉะนั้น ข้ออ้างของหน้อยจึงรับฟังไม่ได้ตามเหตุผลดังกล่าว

วิเคราะห์

การรื้อเรือนไม้สักที่ชำรุดทรุดโทรมแล้วปลูกสร้างใหม่โดยใช้ไม้สักจากเรือนหลังเดิมเป็นส่วนประกอบทั้งหมด เช่นนี้เป็นการกระทำเพื่อรักษาทรัพย์สิน ซึ่งเจ้าของรวมคนหนึ่งๆ อาจกระทำการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรวมคนอื่น กรณีนี้นักศึกษามักจะตอบไขว่เขวว่าเป็นเรื่องของการจัดการตามธรรมดา หรือการจัดการอันเป็นสาระสำคัญ